TEMA VI

EL TESTAMENTO

1. LOS NEGOCIOS JURÍDICOS MORTIS CAUSA: EL TESTAMENTO Y LOS PACTOS SUCESORIOS

La sucesión voluntaria, en cuanto sucesión ordenada conforme a la autonomía de la voluntad del causante, necesita de uno o más negocios jurídicos a través de los cuales la persona pueda manifestar su libertad para disciplinar lo que sucederá con sus relaciones jurídicas después de su muerte. En este sentido, el testamento constituye la forma normal —y casi exclusiva en el Derecho común— de articular voluntariamente una sucesión por causa de muerte. El testamento es un negocio jurídico unilateral mediante el que el causante dispone de sus bienes y derechos de acuerdo con su sola voluntad, y su regulación es el centro neurálgico de las normas sobre sucesión voluntaria. Sin embargo, al lado del negocio jurídico testamentario, existen otros negocios jurídicos cuya finalidad es también la de regular la sucesión. Son los negocios jurídicos bilaterales conocidos con el nombre de pactos o contratos sucesorios. Lo esencial de los pactos sucesorios es que, en ellos, a diferencia de lo que sucede con el testamento, la voluntad ordenadora del causante está vinculada por la de la otra persona que celebra el pacto o contrato con él. La existencia de estos dos grandes tipos de negocios jurídicos *mortis causa* es lo que hace que doctrinalmente se distinga, dentro de la sucesión voluntaria, entre la sucesión testamentaria y la sucesión contractual.

La diferencia entre los negocios jurídicos *mortis causa* y los negocios jurídicos *inter vivos* radica en la diversa finalidad que poseen. La finalidad de los negocios jurídicos *mortis causa* es la de servir como instrumento para regular relaciones o situaciones jurídicas originadas esen-

Scanned with CamScanner

cialmente por la muerte de uno de los sujetos que lo celebran. La muerte del sujeto, en este tipo de negocios jurídicos, es el acontecimiento que da sentido a la regulación negocial, resultando imprescindible para que las situaciones y relaciones jurídicas reguladas por el mismo lleguen siquiera a producirse. Cualquier otro negocio en el que no se eleve la muerte del sujeto a origen esencial de las situaciones y relaciones jurídicas que se regulan es un negocio *inter vivos*.

La diferencia entre el negocio jurídico *mortis causa* y el negocio jurídico *inter vivos* es, en definitiva, de naturaleza causal, es decir, relativa a la finalidad esencial perseguida con el negocio. Nada tiene que ver con su eficacia *post mortem*. Ni los negocios jurídicos *mortis causa* producen únicamente efectos después de la muerte del sujeto que los celebra (piénsese, por ejemplo, que un testamento cuyo único contenido es revocar a otro testamento anterior es sin duda un negocio jurídico *mortis causa*, pero carece de cualquier efecto *post mortem*), ni tampoco los negocios jurídicos *inter vivos* despliegan únicamente su eficacia durante la vida del mismo (es más, pudiera ser que por su duración quepa esperar que sigan produciendo efectos después: *v.gr.*, un préstamo hipotecario con un plazo de amortización de treinta y cinco años, concertado cuando el deudor ya ha cumplido los setenta y cinco).

Así las cosas, es comprensible que las llamadas donaciones *mortis causa*, participen, de acuerdo con lo que dispone el Código, de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad, y se rijan por las normas de la sucesión testamentaria (art. 620 CC). En este tipo de donaciones, como en cualquier negocio jurídico *mortis causa*, el efecto jurídico esencial previsto: la adquisición por el donatario de los bienes donados tras el fallecimiento del donante, no es el resultado de un mero aplazamiento de la eficacia del negocio hasta el momento de la muerte del mismo, sino una consecuencia jurídica establecida, única y exclusivamente, en atención a la situación creada por su muerte. Por esta razón, toda la doctrina y la jurisprudencia exigen que este tipo de donaciones sean esencialmente revocables (*vid.*, el tomo dedicado a los *Contratos* de este Manual), pues se entiende que, si una donación contiene limitaciones a su revocabilidad, ello demuestra que la voluntad del donante no es la mera contemplación de su muerte y la situación que se crea tras la misma, sino que en ella están directamente involucradas consideraciones de naturaleza *inter vivos*.

2. CONCEPTO Y ELEMENTOS ESENCIALES DEL TESTAMENTO

2.1. Concepto y caracteres definitorios del negocio jurídico testamentario

El Código define al testamento como «el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de

parte de ellos» (art. 667). De esta definición se ha dicho que no es completa ni exacta, y con razón. Aún así, nos puede resultar útil para resaltar algunas de las notas esenciales que tradicionalmente se han atribuido al negocio jurídico cuyo estudio comenzamos en este apartado. El testamento es, de conformidad con el artículo 667 CC, un negocio jurídico *mortis causa*. Está destinado, por consiguiente, a regular situaciones y relaciones jurídicas que se producirán después de la muerte del sujeto que lo celebra (el testador), y como consecuencia de dicho fallecimiento; y, además, un negocio jurídico de naturaleza patrimonial.

De las dos notas esenciales enunciadas, sin embargo, solo la primera de ellas se puede mantener en el momento presente sin suscitar controversias. La segunda, por el contrario, que atribuye al testamento la naturaleza de negocio jurídico de carácter patrimonial ha sido excluida, como nota definitoria del testamento, por casi toda la doctrina española. En efecto, como veremos en su momento, dentro del posible contenido del negocio testamentario se incluyen un buen número de disposiciones que carecen de naturaleza patrimonial. El propio Código se refiere, en su artículo 213, a la posibilidad de nombrar en el testamento a un tutor; y el artículo 741 regula la eficacia del reconocimiento de un hijo realizado en testamento. De esta manera, no puede mantenerse ya, ni siquiera desde la perspectiva puramente legislativa, la naturaleza exclusivamente patrimonial del negocio testamentario.

Las restantes notas que caracterizan al negocio jurídico testamentario en el Derecho común español pueden extraerse de otros preceptos del Código Civil, y han sido reiteradamente puestas de manifiesto por la doctrina. En este sentido, el testamento se define, como un negocio jurídico *mortis causa*:

1.º De carácter personalísimo. Así lo dispone expresamente el artículo 670 CC, el cual prohíbe, como consecuencia natural del carácter que se le asigna, que se deje «su formación, en todo o en parte, al arbitrio de tercero», o que se otorgue «por medio de comisario o mandatario». De igual manera, establece este artículo que «tampoco podrá dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia del nombramiento de herederos o legatarios, ni la designación de las porciones en que hayan de suceder cuando sean instituidos nominalmente». En definitiva, salvo disposición excepcional que establezca lo contrario, solo el causante está legitimado para ordenar su sucesión a través de un testamento (STS, Pleno, 15.3.2018 —RJ 1090). Suelen citarse como excepciones a esta regla general, la posibilidad de delegar la facultad de mejorar en el cónyuge del art. 831 CC, la conmutación en metálico de la legítima del art. 841 CC, y la designación de porciones en las que sucederán los herederos no instituidos nominalmente, que resulta posible interpretando el art. 670 CC *a contrario*).

Scanned with CamScanner

2.º De carácter unilateral. La validez y eficacia del testamento, como sucede con cualquier otro negocio jurídico unilateral, se produce como consecuencia de la declaración de voluntad de la única parte del negocio: el testador, emitida en la forma prevista legalmente. Se trata, además, de una declaración de voluntad no recepticia, en la medida en que no resulta necesario, para su plena validez y eficacia, ni siquiera que llegue a conocerse por los destinatarios de la misma. Los demás sujetos que pueden participar en el otorgamiento del testamento, como el notario o los testigos, no son partes del negocio, sino intervinientes por razones atinentes a la forma del testamento.

3.º De carácter unipersonal. En el Derecho español común no es lícito otorgar conjuntamente un testamento por más de una persona. El artículo 669 CC prohíbe el otorgamiento de testamento por parte de «dos o más personas mancomunadamente, o en un mismo instrumento, ya lo hagan en provecho recíproco, ya en beneficio de un tercero». Esta invalidez se extiende al testamento otorgado en el extranjero que se quiera hacer valer en España, y ello aunque las normas del lugar de otorgamiento lo permitan (art. 733 CC). En la propuesta de Código Civil de la APDC, sin embargo, en sintonía con la mayoría de la doctrina[1], se propone prescindir de esta nota característica admitiendo con amplitud la figura del testamento mancomunado.

4.º De carácter formal. Como sucede en todos los negocios jurídicos formales, o para los que se ha previsto la celebración mediante una forma *ad solemnitatem*, el testamento «en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades» que la ley prevé es nulo de pleno Derecho (*ex* art. 687 CC).

5.º De carácter esencialmente revocable. El testamento otorgado por el testador puede ser revocado, modificado o sustituido por una nueva declaración de voluntad testamentaria en cualquier momento, «aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas» (art. 737 CC). A estos efectos, el hecho de que el testamento que revoca al anterior no sea de la misma clase carece de la más mínima relevancia (STS 25.11.2014 —RJ 6006, que estima la revocación parcial de un testamento abierto por medio de un ológrafo).

[1] Cfr. GARCÍA VICENTE, J.R. «El testamento mancomunado: razones para la derogación del art. 669 del Código Civil», en AA.VV. *Derecho de sucesiones. Presente y futuro. XII Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho civil*, Ed. SP de la Universidad de Murcia, Murcia, 2006.

Scanned with CamScanner

2.2. El sujeto del testamento y la capacidad para testar

Definido el testamento como un negocio jurídico unilateral, unipersonal y personalísimo, resulta evidente que solo está legitimado para otorgarlo el causante de la sucesión que pretende regularse a través de sus disposiciones. No cabe, de ningún modo, en materia testamentaria, ni el otorgamiento por vía de representación legal o voluntaria. Sí es lícito, sin embargo, que el testador utilice las medidas de apoyo que necesite para el adecuado ejercicio de su capacidad (art. 249 CC), siempre, claro está, que estas no tengan carácter representativo (como sucedería si el testamento lo otorga el curador con facultades representativas del art. 264 CC), pues en tal circunstancia se estaría contraviniendo el carácter personalísimo del testamento.

La regulación de la capacidad para testar se encuentra en los artículos 663 y 665 CC. El primero de estos preceptos exige las dos condiciones que debe reunir cualquier persona para ser capaz de otorgar testamento: ser mayor de catorce años y tener la aptitud necesaria para conformar y expresar la voluntad testamentaria. La concurrencia de ambos requisitos deberá ser apreciada por el notario en todos los testamentos en los que intervenga (arts. 685 y 696 CC). Respecto del primero de ellos (la edad), debe puntualizarse que, en ciertas modalidades testamentarias, se exige una edad superior (dieciocho años en el testamento ológrafo, de acuerdo con el artículo 688 CC). El segundo requisito, por su parte, exige que el testador posea la tradicional capacidad para entender y querer el acto que se está llevando a cabo, unida a la posibilidad de expresarlo al exterior. Así lo dispone el artículo 665 CC, que ordena al notario apreciar si el testador puede comprender y manifestar el alcance de las disposiciones testamentarias. El notario, para tomar esta decisión, no tiene por qué servirse ni pedir informe médico, todo ello sin perjuicio de su impugnación en sede judicial si se estima por un interesado que existió error en la apreciación (STS 3.2.2023 —RJ 1557). Por otra parte, después de la reforma operada por la Ley 8/2021, el Código Civil establece expresamente que, a la hora de otorgar testamento, es perfectamente lícita la utilización de medidas de apoyo con las que cuente la persona para el adecuado ejercicio de su capacidad, siempre que éstas sean respetuosas con el carácter personalísimo del testamento. Una de estas medidas de apoyo será la intervención del propio notario, el cual, de conformidad con los principios que regulan la discapacidad, debe procurar con su intervención que la persona llegue a adoptar sus propias decisiones atendiendo a su propia voluntad, deseos y preferencias (art. 665 CC).

Existe, en todo caso, una abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo anterior a la reforma que puede seguir siendo útil para determinar el grado de capacidad de comprensión que se exige en el testador. En este sentido, el Tribunal Supremo ha manifestado que la capacidad de comprender el acto debe exigirse, única y exclusivamente, en el mo-

Scanned with CamScanner

mento del otorgamiento (SSTS 13.10.90 —RJ 7863, 28.918 —RJ 4073 y art. 666 CC), y que, en principio, ha de presumirse que concurre en toda persona «como atributo normal de su ser» (SSTS 26.5.95 —RJ 3256, 15.3.2018 — RJ 1090). Igualmente, el Tribunal Supremo ha declarado que este elemento de la capacidad no debe interpretarse como sinónimo de «absoluta integridad», sino más bien como una situación en la que el testador posee las «condiciones que normalmente se estiman como expresivas de la aptitud mental» (STS 27.11.95 —RJ 8717), dentro del parámetro de un «horizonte mental corriente» (STS de 25.9.59 —RJ 1924). Este horizonte mental debe entenderse referido, naturalmente, al de una persona de catorce años (o de dieciocho en el caso del testamento ológrafo). La vigencia del principio *favor testamenti* provoca que para apreciar la incapacidad para testar se requiera una prueba especialmente intensa (STS 7.7.2016 —RJ 3157).

La sanción civil aplicable a los testamentos otorgados por personas incapaces de testar es, de conformidad con la mayor parte de la doctrina[2], la nulidad de pleno Derecho.

2.3. La declaración de voluntad testamentaria y sus vicios

Como sucede con cualquier negocio jurídico, la declaración de voluntad que constituye la esencia del testamento, además de ser emitida por un sujeto capaz y legitimado para celebrar el negocio, ha de ser libremente formada y emitida. Por consiguiente, la presencia de vicios internos o externos que hayan producido una declaración defectuosa afectan a la validez del testamento, al igual que afectan a la del contrato y a la de los demás negocios jurídicos. Sin embargo, las normas sobre los vicios de la voluntad en el testamento son diversas de las dispuestas para los contratos, tanto en lo que se refiere a la enumeración de los vicios relevantes, como en la sanción aplicable por razón de su presencia.

El artículo 673 CC enumera, con carácter general, los vicios de la voluntad que afectan a la validez del testamento, disponiendo que será nulo el otorgado «con violencia, dolo o fraude». Estos tres supuestos de testamento viciado han quedado reducidos doctrinal y jurisprudencialmente a dos: 1.º La violencia, en la que quedarían incluidos tanto los supuestos de violencia física, como los de intimidación o violencia moral, y 2.º El dolo o fraude, que abarcaría todas aquellas situaciones en las que la voluntad del testador ha quedado afectada por la inducción al error, la maquinación o el engaño. En cuanto a su concepto, nos remitimos a lo dicho sobre estos vicios en el Tema XII del Volumen de este Manual dedicado al Derecho privado y al Derecho de la persona.

---

[2] CAPILLA RONCERO, F. «Nulidad e impugnabilidad del testamento», *ADC*, 1987-I, pp. 7 y ss.

Scanned with CamScanner

En la práctica, en materia de vicios de la voluntad, son especialmente frecuentes las controversias sobre captación de la voluntad del testador, inscribibles en el marco del dolo o fraude del artículo 673 CC. Lo cierto es que la jurisprudencia se ha mostrado tradicionalmente bastante restrictiva en la apreciación de los vicios de la voluntad testamentaria, requiriendo una prueba manifiesta y directa de la presencia del vicio (SSTS de 13.10.90 —RJ 7863 y 14.5.96 —RJ 3910). La STS de 25.11.2014 —RJ 6020, que confirma la anulación por dolo de un testamento, es un buen ejemplo de la intensidad probatoria que se requiere en estos casos.

La sanción prevista para los testamentos otorgados con violencia, dolo o fraude es la nulidad, expresión que, mayoritariamente, se entiende sinónima de nulidad de pleno Derecho.

Por último, es preciso efectuar alguna consideración acerca de la falta de mención normativa del error como uno de los eventuales vicios que invalidan la declaración de voluntad testamentaria. La mejor doctrina ha entendido que esta ausencia expresa del error entre los vicios enumerados por el artículo 673 CC no es óbice para concederle relevancia (en contra STS 29.1.08 —RJ 229)[3]. Sin perjuicio de ello, lo que no puede negarse es que existen dos supuestos en los que el Código regula la relevancia del error como circunstancia que puede viciar la voluntad que se encuentra detrás de una disposición testamentaria (arts. 767 y 773 CC).

2.4. La forma del testamento

Ya hemos mencionado que el testamento es un negocio en el que la forma es condición esencial para su validez o, lo que es lo mismo, un negocio jurídico formal. En relación con la forma del testamento, lo primero que le llama la atención a quien se aproxima por vez primera a la regulación del Código es el gran número y la minuciosidad de las disposiciones normativas que la regulan. El fundamento de esta obsesión por la forma del testamento, tan inusual en otros sectores del ordenamiento jurídico civil, se debe a que la declaración de voluntad testamentaria está destinada a producir efectos después de la muerte del testador y, por consiguiente, resulta de la máxima importancia la certeza de que el testamento es realmente el producto de la voluntad del causante. El gran número de formalismos exigidos en relación con las distintas clases de testamentos tiene como finalidad esencial precisamente el asegurar en la mayor medida que sea posible esa certidumbre (STS 4.11.2009 —RJ 5835).

[3] Cfr. GORDILLO CAÑAS, A. «El error en el testamento», en ADC, 1983, pp. 775-779; ÁLVAREZ LATA, N. «Comentario de los arts. 667 a 675», en BERCOVITZ, R. (Dir.) Comentarios al Código Civil, Ed. Thomson-Aranzadi, 2013 (4ª edic.), p. 852.

Scanned with CamScanner

El análisis de la forma del negocio jurídico testamentario en general no resulta posible, toda vez que, en el Derecho común español, se prevé la posibilidad de otorgar el testamento en formas diversas. Los distintos procedimientos formales que se pueden emplear para otorgar testamento suelen estudiarse, y ello es buen indicador de la trascendencia de la forma en este negocio jurídico, como distintas clases de testamento. Siendo así, nos limitaremos a exponer en este apartado aquellas formalidades testamentarias principales, comunes a varias de las distintas clases de testamento, dejando para el siguiente epígrafe las particularidades propias de cada una de ellas.

2.4.1. La identificación del testador

La identificación del testador constituye una exigencia indispensable para que el testamento sea válido, cualquiera que sea la forma en la que se otorgue. En los testamentos en los que debe intervenir un notario se prevé que, cuando el testador no sea conocido por el propio notario, se le identifique, bien mediante la utilización de documentos oficiales expedidos por las autoridades públicas con el objeto de identificar a las personas (DNI o pasaporte), o bien con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo notario (art. 685 CC). Estos últimos son los llamados *testigos de conocimiento*, que se distinguen de los instrumentales, a los que luego nos referiremos, en que su misión se limita a servir como medio de identificación del testador. En caso de que por ninguno de estos medios se pudiese identificar al testador, entonces se ordena al notario que declare esta circunstancia, especificando las señas personales del testador y los documentos de identificación que haya presentado (art. 686 CC). En este último caso, el testamento será impugnable por defecto de forma y «corresponderá al que sostenga su validez la prueba de la identidad del testador». Por otra parte, en relación con el testamento ológrafo, el procedimiento de adveración es el instrumento legalmente previsto para efectuar la identificación que, en este caso, se llevará a cabo tras la muerte del testador (art. 691 CC).

2.4.2. El notario

Cuando es exigida su intervención en el testamento (y así sucede con los testamentos abiertos ordinarios y en todos los cerrados), el notario autorizante habrá de ser hábil para actuar en el lugar del otorgamiento (art. 694 CC). En estos casos, además, se prohíbe que el testador disponga a su favor, o al de su cónyuge, parientes o afines dentro del cuarto grado, de todo o parte de su herencia; a no ser que se trate de algún bien mueble o cantidad de poca importancia en relación al caudal relicto (art. 754 CC). El notario es responsable de los defectos de forma de los

Scanned with CamScanner

testamentos que haya autorizado en las condiciones y con las consecuencias establecidas en los artículos 705 y 715 CC.

2.4.3. *Los testigos instrumentales*

La intervención de testigos instrumentales en los testamentos ha ido perdiendo importancia en las últimas reformas del Código. En la actualidad solamente se exige su actuación en los testamentos abiertos no autorizados por el notario. Por el contrario, en el ámbito de los testamentos notariales, la intervención de testigos instrumentales ha quedado reducida a aquellos supuestos específicamente previstos en la ley (cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento, y cuando sea ciego o no sepa o pueda leer por sí el testamento), o en los que su presencia sea reclamada por el testador o por el notario (art. 697 CC). En estos casos en que es preceptiva la intervención de los testigos instrumentales, estos han de ser idóneos o hábiles. Las causas de inhabilidad están contenidas en los arts. 681 y 682 CC, y resultan también aplicables a los testigos de conocimiento. El TS ha declarado recientemente (STS 19.10.2016 —RJ 4938) que la exclusión del cónyuge como testigo idóneo no es aplicable al conviviente o pareja de hecho del testador.

2.4.4. *El idioma en que se ha realizado la declaración de voluntad testamentaria*

En cuanto al idioma empleado para efectuar la declaración de voluntad testamentaria, el Código permite el otorgamiento del testamento en el idioma que prefiera emplear el testador, extranjero u oficial del Estado o de alguna de sus CCAA (el art. 688 CC permite el otorgamiento de testamento ológrafo en el propio idioma del testador). Ahora bien, el artículo 684 CC dispone que, en caso de que el testamento se otorgue ante notario, y la expresión de la voluntad testamentaria se efectúe en una lengua desconocida para el mismo, se requerirá «la presencia de un intérprete, elegido por aquel, que traduzca la disposición testamentaria a la [lengua] oficial en el lugar del otorgamiento que emplee el notario». La doctrina no se pone de acuerdo en torno a la aplicabilidad o no al traductor, que será elegido por el testador, de las causas de inhabilidad de los testigos, aunque parece razonable la respuesta afirmativa a la cuestión[4]. En cuanto al sentido de la disposición, esta se fundamenta en que no existe un deber del notario de comprender la lengua extranjera en la que se expresa el testador ni las cooficiales de las CCAA. En todo caso, si la lengua oficial que emplea el notario y la también oficial en alguna CA del Estado, que utiliza el testador, son distintas, el docu-

[4] Cfr. VALLET DE GOYTISOLO, J.B. *Panorama del Derecho de sucesiones T.II Perspectiva dinámica*, Ed. Cívitas, Madrid, 1984, p. 53.

Scanned with CamScanner

mento se escribirá en la que elija el otorgante (art. 149 RNot.). En caso de que el testador emplee un idioma extranjero, el documento se podrá redactar solo en español o en las dos lenguas, a decisión del otorgante, y siempre que el notario conozca ambos idiomas. Si no es así, la redacción se efectuará en las dos lenguas, de conformidad con el artículo 150 RNot.

3. CLASES DE TESTAMENTOS

El Código distingue, por razón de las formalidades exigidas para el otorgamiento de unos y otros, entre una amplia gama de testamentos. Estos testamentos se clasifican por el artículo 676 CC en dos grupos: el de los testamentos comunes, que son accesibles para cualquiera que desee testar; y el de los testamentos especiales, que solamente pueden ser empleados cuando concurren ciertas circunstancias específicas. Son testamentos comunes el testamento abierto, el cerrado y el ológrafo; y pertenecen al grupo de los testamentos especiales el testamento militar, el marítimo y el hecho en país extranjero (art. 677 CC). En cualquier caso, dentro de los testamentos comunes, también existen variaciones derivadas de la presencia de circunstancias especiales que pueden producir alteraciones en su forma normal.

3.1. El testamento abierto

El artículo 679 CC define al testamento abierto como aquel en el que «el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone». La nota esencial que caracteriza a este tipo de testamento es, por lo tanto, la publicidad, la falta de confidencialidad tanto en lo que se refiere a la voluntad de testar como al propio contenido del testamento. En la modalidad ordinaria o común del testamento abierto, la persona encargada de autorizarlo es el notario (dando lugar al llamado testamento abierto notarial), y junto a ella, la ley establece dos modalidades extraordinarias o especiales: el testamento en peligro de muerte y el testamento en caso de epidemia, que se otorgan ante testigos.

El testamento abierto notarial es, sin lugar a dudas, la forma testamentaria más frecuente en la práctica. Posee indudables ventajas respecto de los demás testamentos: el notario puede efectuar una labor de asesoramiento técnico, simultánea a la redacción del testamento, que siempre resulta conveniente para un testador lego en Derecho. Además, el testamento se constituye como documento público desde el primer momento y se conserva en el protocolo del notario autorizante. Por último, este testamento no ocasiona ningún gasto posterior al propio otorgamiento.

Scanned with CamScanner

El otorgamiento de esta modalidad testamentaria se regula por el Código distinguiendo las siguientes fases:

1.º *Fe de conocimiento y juicio de capacidad del testador*. El notario autorizante ha de dar fe de la identidad del testador. Igualmente debe hacer constar en el acta de otorgamiento que, a su juicio, el testador tiene la capacidad legal necesaria para otorgar testamento (art. 696 CC). La omisión de la fe de conocimiento o de capacidad produce la nulidad del testamento (STS 25.2.90 —RJ 4892).

2.º *Expresión de la voluntad testamentaria por parte del testador*. El testador otorgante puede expresar su voluntad por escrito, a través de una minuta o borrador que se presenta al notario, u oralmente. Esta expresión de voluntad debe ser recibida tanto por el notario autorizante como, en su caso, por los testigos instrumentales, y debe realizarse personalmente por el testador. De otro modo, el testamento será nulo.

3.º *Redacción del testamento por el notario*. Enterado de cuál es la voluntad del testador, el notario redactará el testamento, dándole a la voluntad que se le ha manifestado una forma ajustada a Derecho. En el documento redactado por el notario, habrá de hacerse constar el lugar, año, mes, día y hora del otorgamiento (art. 695 CC); localizando así el instrumento en un momento temporal y geográfico específico sobre la base del cual poder enjuiciar la habilidad del notario, la capacidad del testador o la eventual revocación del testamento.

4.º *Lectura notarial del testamento*. El notario habrá de leer, a continuación, en voz alta y en su integridad el testamento que ha redactado, advirtiendo al testador de que también puede leerlo él mismo si así lo desea. En el caso de que el testador tenga alguna dificultad o le resulte imposible leer el testamento u oír su lectura por parte del notario, éste tiene el deber de utilizar todos los medios técnicos, materiales o humanos que sean precisos para asegurarse de que el testamento recoge fielmente su voluntad y de que ha entendido la información, explicaciones o aclaraciones que le haya dado sobre el mismo (art. 695 CC).

5.º *Manifestación de conformidad y firma del testamento*. Una vez leído, el testador, habiendo comprobado la adecuación del contenido del acta a su voluntad, deberá manifestar su conformidad. Esta conformidad se hará constar en el testamento (STS 4.5.77 —RJ 1946). Asimismo, y en caso de que concurra la conformidad, el testamento deberá ser firmado por el testador, por sí mismo o por medio de sus testigos en el supuesto previsto por el artículo 697.1.º CC (STS 20.3.12 —RJ 5120). La expresión de una causa o razón falsa acerca de la imposibilidad de firmar del testador, es considerada por la jurisprudencia mayoritaria como motivo de nulidad (SSTS 16.6.97 —RJ 5411 y 29.4.99 —RJ 2618). También deben firmar el testamento el notario y los demás asistentes,

Scanned with CamScanner

en su caso, al acto de otorgamiento (testigos de conocimiento, testigos instrumentales, intérprete y facultativos).

Las formalidades del testamento abierto notarial que quedan enmarcadas entre la lectura del testamento por el notario y la firma del mismo, han de practicarse en un solo acto, sin que sea lícita interrupción alguna «*salvo la motivada por algún accidente pasajero*» (art. 699 CC). Rige por tanto el principio de unidad de acto, con el fin de evitar en el mayor grado posible influencias sobre la voluntad del testador. Se trata, en todo caso, de una unidad de acto atenuada, toda vez que ciertas formalidades, como la expresión de voluntad del testador, o la redacción del testamento por el notario quedan fuera de la regla (STS 30.11.91 —RJ 8582). La ruptura de la unidad de acto produce la nulidad del testamento.

Finalmente, debemos referirnos a las dos modalidades extraordinarias de testamento abierto, las cuales solamente resultan accesibles al testador que se encuentre en alguna de las situaciones fácticas previstas por las normas que las regulan. La primera de ellas es el llamado testamento en peligro de muerte o *in articulo mortis*, el cual solamente puede otorgarse, con las formalidades dispuestas por los artículos 700 y 702 CC, cuando el testador se encuentra en «*peligro inminente de muerte*» (STS 4.10.57 —RJ.2845—, 2.7.77 —RJ 3256— y 4.11.2009 —RJ 5835). La segunda modalidad extraordinaria de testamento abierto es la del testamento en caso de epidemia. Esta modalidad ha generado una importante literatura durante la pandemia provocada por el SARS-Cov-2, sin que todavía esté claro en qué medida se ha extendido su uso en la realidad. Para poder emplearlo, la epidemia ha de constituir un acontecimiento público y notorio que debe impedir razonablemente el otorgamiento ante notario, y permite a los eventualmente afectados otorgar testamento por escrito, ante tres testigos mayores de dieciséis años (arts. 701 y 702 CC). Las dos modalidades extraordinarias de testamento abierto están sujetas a plazos de caducidad y deben elevarse a escritura pública y se protocolizan (arts. 703 y 704 CC).

3.2. El testamento cerrado

El testamento cerrado es definido por el artículo 680 CC como aquel en el que el testador, sin revelar su última voluntad, declara que esta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto. Esta modalidad testamentaria se caracteriza, en primer término, porque el testamento siempre se celebra ante notario y, en segundo lugar, porque al notario no se le da a conocer el contenido de la voluntad testamentaria. Con ella, se trata habilitar un instrumento que permite compatibilizar la confidencialidad del contenido del testamento con las garantías que supone el otorgamiento notarial. De cualquier modo, tiene escasa virtualidad práctica, habida cuenta de lo complicado

Scanned with CamScanner

que resulta su otorgamiento, y el coste que supone su apertura y protocolización.

El testamento cerrado habrá de ser necesariamente escrito y, en principio, redactado por el testador de su puño y letra, con su firma al final del documento (art. 706.I CC). Su otorgamiento se encuentra vedado para quienes no sepan o puedan leer (art. 708 CC), puesto que no está al alcance de estas personas constatar por sí mismas la coincidencia entre su voluntad y el contenido del documento. Sin embargo, sí pueden otorgarlo las personas con discapacidad visual y las que no saben o no pueden escribir o firmar, las primeras en las condiciones dispuestas por el artículo 708.II CC, y las segundas en las de los arts. 706.III y IV CC.

Una vez confeccionado el testamento de la manera indicada ha de presentarse ante notario. Al acto de otorgamiento deberán acudir, además del testador y del notario, dos testigos instrumentales en los supuestos del artículo 707.5.° y 7.° CC. El otorgamiento se efectúa cumpliendo con las siguientes formalidades (art. 707 CC), que, de conformidad con la doctrina mayoritaria[5], se llevarán a cabo de acuerdo con el principio de unidad de acto:

1.° Se sitúa el documento escrito que contiene el testamento en una cubierta susceptible de ser cerrada y sellada, de modo que no se pueda extraer de la misma sin romperla.

2.° Se comparece ante el notario con el documento ya cerrado y sellado, o se cierra y se sella ante la presencia del notario.

3.° El testador manifiesta al notario, por sí o, en su caso, por medio de intérprete, que el documento que presenta contiene su testamento, expresando cuál ha sido el modo empleado para su redacción y quién lo ha firmado y dónde, de conformidad con el artículo 706 CC.

4.° El notario, recibido el documento, extiende el acta de otorgamiento sobre la cubierta del testamento, dando fe acerca de la identidad del testador (el cual será identificado por el notario de acuerdo con las reglas generales) y sobre su capacidad. En el acta se deberá indicar, además, el lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento y, si procede, la circunstancia de que el testador no sabe o no puede firmar.

5.° Extendida y leída el acta, se firma por el testador o, si no sabe o no puede firmar, por un testigo idóneo a su ruego, así como por el notario autorizante y demás asistentes al acto de otorgamiento.

[5] Vid., por todos, MARTÍNEZ ESPÍN, P. «Comentario de los arts. 676 a 743», en BERCOVITZ, R. (Dir.) *Comentarios al Código Civil*, Ed. Thomson-Aranzadi, 2013 (4ª edic.), p. 883.

6.º Tras haber sido autorizado por el notario, y ser unida al protocolo corriente del mismo una copia autorizada del acta de otorgamiento, el testamento se entrega al testador (art. 710 CC). A partir de aquí el testador puede decidir guardar el testamento él mismo, entregárselo a una persona de confianza o depositarlo en la Notaría. En este último caso, el notario dará recibo al testador y hará constar que el testamento queda en su poder en el protocolo correspondiente (art. 711 CC).

7.º Si el testamento fue depositado ante el notario autorizante, este deberá comunicar su existencia, en el plazo de diez días desde que tenga conocimiento del fallecimiento del testador, al cónyuge sobreviviente, a los ascendientes y a los descendientes del testador. De no conocer la identidad o domicilio de estas personas, o si ignorase su existencia, el notario deberá dar al testamento la publicidad que determine la legislación notarial. El incumplimiento de este deber determinará la responsabilidad del notario por los daños y perjuicios que pudiera haber causado (arts. 712.2 y 3 CC)

8.º Si el testamento no fue depositado en poder del notario autorizante, una vez fallecido el testador, se presentará el testamento por la persona depositaria ante notario competente en el plazo de diez días contados desde que tenga conocimiento de la muerte. Si se incumple este plazo, el obligado a presentarlo responderá de todos los daños y perjuicios que se deriven de la falta de presentación (art. 712 CC), perdiendo su derecho a la herencia en caso de dolo (art. 713 CC). Tras la presentación del testamento ante el notario competente, este procederá a comunicar la existencia del mismo del modo señalado en el artículo 712.2 y 3 CC.

9.º El testamento será abierto y protocolizado de conformidad con lo establecido en la legislación notarial (art. 714 CC).

como un testamento abierto)

Junto a la modalidad ordinaria de testamento cerrado que acabamos de exponer, el Código Civil regula una modalidad extraordinaria, reservada únicamente para aquellos supuestos en los que el testador sabe escribir, pero no puede expresarse oralmente (art. 709 CC).

En caso de que el testamento cerrado sea nulo por no haberse cumplido las formalidades establecidas (art. 687 CC), cabe la posibilidad de que conserve su validez mediante su conversión en testamento ológrafo. Esta posibilidad de salvar la validez del testamento cerrado se deriva de lo dispuesto en el artículo 715 CC, el cual, amén de referirse a la eventual responsabilidad del notario si el defecto de forma se debió a su malicia o negligencia inexcusable, dispone la eventual validez del testamento como ológrafo si todo él estuviere escrito y firmado por el testador y tuviere las demás condiciones propias de este testamento.

Scanned with CamScanner

3.3. El testamento ológrafo

De acuerdo con el artículo 678 CC, el testamento ológrafo es aquel que el testador escribe por sí mismo, en la forma y con los requisitos que se determinan en el artículo 688. El ológrafo es un testamento celebrado en documento privado, sin intervención de notario ni de testigos, sin excesivas formalidades y ningún gasto de otorgamiento. Al lado de estas virtudes del testamento ológrafo, sin embargo, deben ponderarse como desventajas la falta de las garantías que siempre ofrece el otorgamiento notarial del testamento en cuanto a la posibilidad de que sea sustraído, alterado o falsificado; así como la ausencia de asesoramiento técnico que puede conducir a una errónea plasmación de la voluntad del testador.

Una peculiaridad de este tipo de testamento es que la propia afirmación de su existencia depende de la concurrencia de una condición previa. Esta condición previa consiste en que del contenido del documento que pretende hacerse valer como testamento ológrafo, debe poder deducirse con certeza la voluntad del testador de hacer testamento. Esto significa que del documento debe poder inferirse con seguridad que la voluntad del redactor era la de disponer *mortis causa* de todos sus bienes o de parte de ellos (art. 667 CC), quedando excluidos de esta condición todos aquellos documentos en los que se recojan meros esbozos, proyectos o anotaciones referentes al eventual destino de los bienes después de la muerte del redactor (STS 10.12.56 —RJ 3860 y 18.6.94 —RJ 6022).

En lo que se refiere a la capacidad para testar, el artículo 688 CC eleva la edad mínima exigida, cuando se trata de otorgar este tipo de testamento, a la mayoría de edad, a causa del mayor peligro de captación o suplantación de la voluntad del testador que conlleva[6].

Los requisitos de forma establecidos para el testamento ológrafo se contienen en el artículo 688 CC. De conformidad con su definición legal, esta regulación parte de la necesidad que se redacte por escrito. Además, exige, como requisito esencial para su validez, la redacción del mismo, en su totalidad, de puño y letra del testador y con su grafía habitual [STS 21.6.2018 —RJ 3238)]. En todo caso, el hecho de que un tercero, con posterioridad al otorgamiento, intercale o añada palabras al documento no es, obviamente, un motivo para anularlo (SAP Salamanca 1.6.99-AC 976). El testamento ológrafo ha de ser firmado por el testador y, en el mismo, tiene que constar la fecha en que se otorga, con expresión, del día, mes y año (STS 25.11.2014 —RJ 6006). La ausencia de estos extremos, imprescindibles para ponderar la capacidad del testador

[6] Sobre el actual problema del testamento ológrafo otorgado por personas mayores dependientes, vid. DÍAZ ALABART, S. *El testamento ológrafo de las personas mayores dependientes*, Ed. Reus, Madrid, 2018.

y la eventual revocación del testamento, es causa de nulidad. La fecha que se haya hecho constar en el documento ha de ser la fecha del otorgamiento, que no tiene por qué coincidir con la de la redacción del mismo, puesto que nada obsta a que antes del texto definitivo [el testador] haga bosquejos, borradores o proyectos, o lo extienda con la idea de reflexionar posteriormente sobre lo escrito (STS 10.2.94 —RJ 848). Por último, en caso de que el testamento ológrafo contenga palabras enmendadas, tachadas o escritas entre renglones, todas ellas han de ser salvadas por el testador con su firma para que sean válidas. De otro modo se considerarán no puestas (SSTS 24.2.61 —RJ 351 y 4.11.61 —RJ 4436).

Tras el fallecimiento del testador, el testamento ológrafo no será eficaz hasta que se proceda a su adveración y protocolización:

Adveración. Para la adveración o comprobación de la autenticidad del testamento ológrafo, el artículo 689 CC prescribe que este se presente ante notario dentro del plazo de cinco años contados desde el día de la muerte, por quien lo tenga en su poder, o por cualquiera que tenga interés en su presentación. El transcurso de este plazo determina la caducidad del testamento. Distinto del término quinquenal al que acabamos de referirnos es el plazo de diez días que el artículo 690 CC concede a la persona en cuyo poder se encuentra el testamento, desde que haya tenido noticia de la muerte del testador, para que lo presente ante el notario. Este breve plazo no produce efecto alguno sobre la validez del testamento. La consecuencia de su transcurso es el nacimiento de la obligación del poseedor del documento de indemnizar, con cargo a su patrimonio, cualquier daño que pudiera derivarse de su falta de presentación.

La adveración puede conseguirse, bien directamente en un proceso contencioso (STS 16.6.2015 —RJ 2529), o bien ante el notario. En este segundo caso, presentado el testamento ante el notario y probada la muerte del testador, se procederá a comprobar la autenticidad del documento por parte del escribano de conformidad con lo establecido en la legislación notarial. Ahora bien, tanto si se formula oposición a la adveración en los trámites seguidos ante el notario, como si los legitimados acuden directamente a un procedimiento judicial contencioso (SSTS 17.11.66 —RJ 5878 y 14.5.96 —RJ 3910), la adveración será ventilada en un juicio declarativo ordinario.

Protocolización. En el momento en que el notario decida que el testamento ológrafo es auténtico, él mismo autorizará el acta de protocolización. Si, por el contrario, el testamento no fuera adverado, por entender el notario que no se ha acreditado suficientemente la identidad del otorgante, se procederá al archivo del expediente sin protocolizar aquel. Autorizada o no la protocolización del testamento ológrafo, los interesados no conformes podrán ejercer sus derechos en el juicio que corresponda (art. 693 CC).

Una última cuestión que normalmente es objeto de tratamiento con ocasión del análisis del testamento ológrafo, a causa de la identidad existente en cuanto a su régimen de requisitos formales, es la atinente a las denominadas *memorias o cédulas testamentarias*. Por este nombre se conoce a las cédulas o papeles privados a los que se ha referido el testador en su testamento al disponer sobre institución de heredero o sobre mandas o legados (art. 672 CC). Se trata, por consiguiente, de documentos en los que el testador ha hecho constar atribuciones *mortis causa*, y que, apareciendo tras su muerte, pueden llegar a adquirir relevancia en la ordenación de la sucesión. Respecto de estos documentos, se ha discutido largamente si se trata de auténticos testamentos, o de simples complementos de una voluntad testamentaria manifestada *per relationem* (es decir, que necesita ser integrada mediante el contenido de estas memorias). En este sentido, lo único indudable es que, testamento o no, las memorias o cédulas testamentarias deben satisfacer los mismos presupuestos exigidos para la validez del testamento ológrafo, siendo en caso contrario nulas (STS 4.11.2009 —RJ 5835).

3.4. Los testamentos especiales

De conformidad con lo establecido en el artículo 677 CC, son testamentos especiales el militar (arts. 716 a 721 CC), el marítimo (arts. 722 a 731) y el hecho en país extranjero (arts. 732 a 736). La condición de especiales de estos testamentos radica en que solo pueden ser empleados cuando concurren circunstancias extraordinarias, cuya presencia resulta indispensable para su validez. A causa de su excepcionalidad, las situaciones extraordinarias que habilitan para su otorgamiento han de ser interpretadas restrictivamente, quedando excluida su utilización en otras análogas (STS 10.7.44 —RJ 911).

4. EL CONTENIDO DEL TESTAMENTO

En el testamento, el causante ordena lo que debe hacerse después de su muerte con sus bienes y relaciones jurídico-patrimoniales y, en lo que sea disponible, con sus relaciones jurídicas familiares y personales. Dentro de las diversas disposiciones que el testador puede incluir en el testamento destaca, sin duda alguna, la designación de uno o varios herederos. Mediante la denominada «institución de heredero» el testador designa sucesor a título universal de sus bienes a una persona, el llamado instituido o, simplemente, heredero. El heredero es, por lo tanto, aquel sucesor del difunto que pasa a ocupar la misma posición que ostentaba aquel en todo o, si concurre con otros herederos, en una parte alícuota del caudal hereditario. La institución de heredero constituye la primera y cualitativamente más importante de las disposiciones típicas de un testamento. Al lado de ella, y como segunda disposición

Scanned with CamScanner

testamentaria típica se encuentra el legado. A través de este, el testador efectúa una atribución singular en beneficio de una persona, por la cual, normalmente, la convierte en sucesor a título particular en la relación o relaciones jurídicas objeto de la misma (aunque veremos que en determinados legados el legatario en nada sucede al causante).

Institución de heredero y legado constituyen, sin duda, las dos disposiciones testamentarias típicas principales. Ahora bien, a lado de ellas pueden incluirse en el contenido del testamento una amplia gama de disposiciones, tanto típicas (en el sentido técnico de previstas en la ley), como atípicas.

4.1. El régimen jurídico general de las disposiciones *mortis causa*

Dentro del Capítulo II del Título III del Código Civil («De la herencia») se contienen una serie de normas (en sus Secciones 1.ª, 2.ª y 4.ª) todas las cuales constituyen el régimen jurídico general aplicable a las dos principales disposiciones *mortis causa*: la institución de heredero y el legado (se trata de los arts. 744 a 773 y 790 a 805 CC). Aunque algunas de ellas, concretamente las contenidas en la Sección 2.ª, se refieren expresamente solo a la institución de heredero, lo cierto es que resultan aplicables tanto a las disposiciones a título universal de bienes, como a las realizadas a título particular, así como, en muchos aspectos, a otras disposiciones que puedan contenerse en el testamento.

4.1.1. La designación del instituido

4.1.1.1. Legitimación para efectuar la designación

Los herederos y los legatarios han de ser instituidos por el testador. Se encuentra, por consiguiente, prohibida la delegación en un tercero de la designación de los mismos. Esta prohibición, contenida en el artículo 670.II CC, es consecuencia del carácter personalísimo del negocio jurídico testamentario. Y por la misma razón, el referido precepto prohíbe que se deje en manos de un tercero la subsistencia del nombramiento de los herederos o legatarios previamente designados por el testador, ni la de las porciones en que hayan de suceder cuando hayan sido instituidos nominalmente.

De cualquier manera, el principio sentado en el artículo 670 CC conoce ciertas modulaciones, producidas por medio de normas que permiten, de un modo u otro, la intervención de terceros en la determinación del contenido de la institución de heredero o en el legado. En este sentido, debe mencionarse al artículo 831 CC, que permite delegar en el cónyuge la facultad de mejorar y distribuir la herencia del otorgante;

Scanned with CamScanner

cuyo ejercicio, obviamente, influye en la porción de la herencia que corresponde a cada heredero; así como a las normas que rigen la llamada sustitución pupilar o ejemplar, con las que se permite, de algún modo, al sustituyente testar por el sustituido. También el artículo 671 CC supone la introducción de una modulación en la rigidez del principio, al permitir al testador encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje en general a clases determinadas como a los parientes, a los pobres o a los establecimientos de beneficencia, así como la elección de las personas o establecimientos a quienes aquellas deban de aplicarse.

4.1.1.2. Certeza del designado

El beneficiario de la disposición *mortis causa* no solo ha de ser designado por el testador, sino que debe serlo de forma cierta. La certeza de la institución de heredero o legatario es una condición esencial de su eficacia. Así lo dispone el artículo 750 CC, el cual declara nula toda disposición en favor de persona incierta, a menos que por algún evento pueda resultar cierta. Se requiere, por lo tanto, una designación que permita la identificación del instituido, bien en el momento del otorgamiento, bien en otro posterior, y ya sea de forma nominativa o por otros elementos que la hagan posible.

La forma nominativa de designación se encuentra regulada en el artículo 772 CC, que señala que, cuando se emplee, se identificará al heredero (o al legatario) por su nombre y apellidos, y cuando haya dos que los tengan iguales deberá señalar alguna circunstancia por la que se conozca al instituido.

En todo caso, se permite la identificación del instituido de cualquier otra manera, siempre que se trate de una determinación clara, precisa e individualizada, que palmariamente muestre como el designado fue contemplado singularmente al hacer la declaración de voluntad (STS 4.5.66 —RJ 2290), esto es, de tal manera que no pueda dudarse de quién se trata (art. 772 CC).

4.1.1.3. Relevancia de los motivos de la designación

Una cuestión que enlaza directamente con los modos no nominativos de designar sucesor, aunque no solo con ellos, es el de la causa falsa de la designación (por causa debe entenderse aquí el motivo que ha conducido al testador a efectuar la atribución a título de heredero o de legatario). El artículo 767 CC establece que la causa falsa en la designación de heredero (también aplicable a los legados) se tendrá por no puesta, a no ser que del testamento resulte que la institución no se hubiese hecho de no ser cierta la causa. De este modo, una designación en la que se

Scanned with CamScanner

instituya heredero o legatario «a mi cónyuge, «D...» solo podrá ser anulada, tras un eventual divorcio, en caso de que la condición de cónyuge aparezca como la circunstancia que determinó la institución (RDGRN 26.11.81 —RJ 8541; SSTS 26 y 28.9.18 —RJ 4258 y 4071).

4.1.1.4. Relevancia del error en los datos empleados para efectuar la designación

El error en la expresión de los datos que se han empleado para identificar al instituido heredero o legatario carece de relevancia, siempre que se pueda identificar al instituido de cualquier otra forma (art. 773 CC).

4.1.1.5. Designaciones abstractas o genéricas

La regla de la certeza de la designación de heredero o legatario, sin embargo, conoce ciertas excepciones. Concretamente se permite una designación abstracta o genérica en los siguientes supuestos:

1.º La institución realizada en favor del alma. Se trata de una disposición de todo o parte de los bienes del testador para sufragios y obras piadosas. En estos supuestos se dará a los bienes el destino previsto en el artículo 747 CC.

2.º La institución realizada a favor de los pobres. Cuando se dispone de todo o parte de los bienes de la herencia a favor, sin más, «de los pobres», el artículo 749 CC establece el tratamiento que deberá darse a dichos bienes.

3.º La institución realizada a favor de los parientes. En este caso, y si no se especifican en modo alguno los parientes a los que se dejan los bienes, la designación se entiende efectuada a favor de los más próximos en grado (art. 751 CC). Serán de aplicación al supuesto, con carácter general, las normas sobre sucesión intestada. Quedarán excluidas de esta aplicación, sin embargo, la regla de la limitación del cuarto grado y todo lo referente a la sucesión del cónyuge (que no es un pariente en sentido estricto).

4.1.1.6. Designaciones colectivas y designación sin atribución de cuotas

Un último problema que debe ser tratado en sede de designación en la disposición por causa de muerte es el de los nombramientos colectivos. Con este término se hace referencia a aquellos supuestos en los que el testador efectúa una atribución, a título universal o particular,

Scanned with CamScanner

y señala a varias personas como beneficiarias de la misma. El Código Civil ha tratado de resolver los problemas que plantean este tipo de designaciones a través de reglas de interpretación o de integración de la voluntad del testador.

1.º Si el testador designa a unos beneficiarios de la atribución individualmente y a otros colectivamente («Instituyo herederos a mis hijos, y a D...»), los designados colectivamente se considerarán designados individualmente, salvo que de modo claro conste que fue otra la voluntad del testador (art. 769 CC).

2.º Si el testador instituye a sus hermanos, y los tiene de doble vínculo y solo de padre o madre, se dividirá la herencia entre ellos de acuerdo con las normas sobre sucesión intestada (art. 770 CC).

3.º Si el testador llama a la sucesión a una persona y a sus hijos, se entenderán todos instituidos simultáneamente y no sucesivamente (art. 771 CC). La regla interpreta que, en estos casos, la voluntad del testador es la de excluir la operatividad de las sustituciones fideicomisaria o vulgar, en congruencia con lo dispuesto por el 785.1.º CC.

4.º Los herederos o legatarios instituidos sin designación de partes heredarán por partes iguales (art. 765 CC), sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la existencia de legítimas.

4.1.2. La disposición sometida a condición, término o modo

La institución de heredero y el legado pueden efectuarse de manera pura y simple, pero también someterse a condición, término o modo (art. 790 CC), siempre, claro está, que no se vulneren las reglas sobre intangibilidad de la legítima[7]. Las normas generales sobre obligaciones condicionales son subsidiarias de las específicamente dictadas para las disposiciones *mortis causa* (art. 791 CC).

4.1.2.1. La institución condicional

Las condiciones a las que se sujete la eficacia de las disposiciones testamentarias han de ser lícitas y posibles. Si no es así, se tendrán por no puestas (art. 792 CC, que establece la regla contraria a la contenida en sede de obligaciones condicionales para los mismos supuestos —art. 1.116 CC), manteniéndose la plena eficacia de la disposición a la que afectan. Dentro de las condiciones ilícitas deben incluirse las con-

[7] Vid. sobre este tipo de disposiciones, QUESADA GONZÁLEZ, M.ª C. *La institución de heredero sometida a condición, a término o a modo*, Ed. Reus, Madrid, 2019.

tenidas en los artículos 793.I y 794 CC. En ellos se establece, en primer lugar (art. 793.I CC), la nulidad de la condición de no contraer primero o ulterior matrimonio, a menos que el que la haya impuesto sea el difunto cónyuge del beneficiario de la atribución o los ascendientes y descendientes del mismo. La jurisprudencia ha declarado que solo cabe predicar la nulidad de la condición de no contraer matrimonio sin más, pero no la de no contraer matrimonio con una persona determinada, o no hacerlo hasta una determinada fecha o durante cierto tiempo (SSTS 10.6.65 —RJ 3606 y 28.10.81 —RJ 4676). Por su parte, el CC dispone la validez de un legado por el tiempo que se mantenga la viudez o soltería (art. 793.II CC). El segundo precepto mencionado (art. 794 CC) prohíbe la institución a condición de que el designado haga en su testamento alguna disposición a favor del testador o de otra persona (la llamada condición captatoria), con fundamento en el peligro que supone para la libertad de testar. En todo caso, debe advertirse que este tipo de condiciones solo serán nulas cuando con ellas el testador persiga disponer de un bien ajeno o desvirtuar el carácter personalísimo y gratuito del testamento (STS 5.12.2018 —RJ 5392). En relación con las condiciones captatorias, por otra parte, el Código Civil se aleja de lo establecido con carácter general en relación con las condiciones ilícitas anulando, en este caso, no solo la condición, sino también la disposición testamentaria sujeta a la misma. Además de las referenciadas, también son condiciones prohibidas la de no impugnar el testamento (art. 675.II CC) y la de no promover el juicio de división de herencia.

Dentro de los distintos tipos de condiciones, se admite la utilización tanto de las puramente potestativas, como de las casuales y de las mixtas.

1.º Las puramente potestativas han de ser cumplidas por el heredero tras la muerte del testador, salvo que su cumplimiento ya se haya producido antes y no pueda reiterarse (art. 795 CC). Si se tratase de una condición potestativa negativa (de no hacer o no dar), se exige al instituido que afiance que no hará o no dará lo dispuesto por el testador (es la llamada caución muciana), obligándosele, en caso de contravención, a devolver lo percibido en virtud del testamento, con sus frutos e intereses (art. 800 CC). Un problema interesante que se plantea respecto de estas condiciones se refiere a lo que sucede cuando la condición no se cumple, sin culpa del instituido. Para resolver este problema, se ha aplicado lo dispuesto en el artículo 798 CC respecto del incumplimiento de la carga modal; de manera que, si la condición se incumplió por causas ajenas a la voluntad del instituido bajo ella, debe entenderse cumplida (STS 9.5.90 —RJ 3696).

2.º Si la condición fuese casual o mixta, bastará con que la condición se cumpla en cualquier tiempo, antes o después de la muerte del testador, salvo que se haya dispuesto otra cosa en el testamento (art. 796.I CC). La

Scanned with CamScanner

única excepción a esta última regla se refiere a aquella condición que ya se ha cumplido antes del otorgamiento del testamento sabiéndolo el testador; en tal caso solo se tendrá por cumplida cuando sea de tal naturaleza que no pueda ya existir o cumplirse de nuevo (art. 796.III CC).

Además de estas tres clases de condiciones, resulta también admisible la utilización de condiciones de carácter suspensivo y resolutorio, aunque a estas últimas (prohibidas en Derecho romano por la vigencia del principio *semel heres semper heres*) no les dedica el Código ni un solo precepto. Conviene examinar sus efectos, distinguiendo el período en el que el cumplimiento de la condición está pendiente, del momento posterior a su cumplimiento.

1.º Pendiente la condición suspensiva, el instituido no es ni heredero ni legatario. No puede, por tanto, el heredero condicional aceptar ni repudiar la herencia (art. 991 CC); ni tampoco disponer *inter vivos* o *mortis causa* con plena eficacia de su derecho (art. 759 CC, aunque sí puede disponer de su derecho cuando se trate de un término incierto, *vid.*, art. 799 CC cuyo tenor literal debe interpretarse en este sentido para salvar la contradicción entre el mismo y el 759 CC). En todo caso, se considera al instituido titular de una expectativa de derecho susceptible de ser protegida (STS 3.4.65 —RJ 1979), y se ha admitido que puede transmitir su derecho siempre que se tenga presente el carácter condicional del mismo (STS 5.5.83 —RJ 2669). Durante este período los bienes de la herencia serán administrados por los sujetos determinados en los artículos 802 a 804 CC.

Cuando la condición es resolutoria, el instituido lo está desde el mismo momento en que se abre la sucesión. Por consiguiente, puede aceptar o repudiar la herencia; y en caso de que acepte, disponer sobre los bienes hereditarios, aun cuando los efectos de los negocios de disposición se extingan con el cumplimiento de la condición (STS 17.3.66 —RJ 1227). Aunque el CC no lo regule expresamente, debe entenderse necesario también para este tipo de condiciones el establecimiento un régimen de administración o afianzamiento. Lo decisivo cuando existen situaciones de pendencia como las que generan estas condiciones es garantizar el resultado final, y ello es de muy difícil consecución sin este tipo de cautelas.

2.º Cumplida la condición suspensiva, el instituido se convierte en heredero o legatario con efecto retroactivo al día de la apertura de la sucesión. Es en este momento de cumplimiento de la condición cuando el instituido debe, en su caso, aceptar o repudiar la atribución, así como ostentar la capacidad necesaria para suceder.

El cumplimiento de la condición resolutoria, por el contrario, supone la pérdida de la condición de heredero o legatario y, dependiendo de

Scanned with CamScanner

las circunstancias, dará lugar, si se trata de una institución de heredero, al derecho de acrecer o a la apertura de la sucesión intestada, y si se trata de un legado, a su refundición en la masa de la herencia.

4.1.2.2. La institución a plazo o término

La regulación de este tipo de disposición testamentaria admite, como la institución condicional, tanto la modalidad de término inicial o suspensivo como la de término final o resolutorio (art. 805 CC). En el primer caso, el instituido no será llamado hasta que llegue el día fijado como término inicial, y en el segundo, el instituido tendrá dicha condición hasta que concluya el plazo establecido por el testador. Durante el tiempo que el instituido a plazo tiene que esperar para adquirir su derecho, o tras haber perdido su condición, el llamado es el sucesor abintestato (art. 805 CC), que tendrá que prestar caución suficiente para entrar en posesión de los bienes (aunque el último inciso del art. 805 CC parece limitar injustificadamente esta obligación a los supuestos de término inicial). Todo ello, claro está, siempre que el testador no haya designado un sustituto para el instituido durante estos períodos temporales.

4.1.2.3. La institución con carga modal

La institución de heredero o legatario con carga modal o *sub modo* es aquella que lleva aparejada, como carga, una obligación para el instituido. De este modo el instituido con carga modal, al tiempo que recibe la atribución patrimonial universal o singular, adquiere igualmente el deber de cumplir con dicha obligación. Debe precisarse que la institución modal no supone ningún obstáculo inicial para la efectividad de la institución. El heredero o legatario recibe una atribución del testador que resulta exigible «desde luego», aunque esté gravada con el modo. Modo y condición se diferencian precisamente en que, mientras la condición hace depender los efectos de la institución del cumplimiento de la misma, el modo vincula al instituido a la ejecución de la obligación impuesta como carga, pero no hace depender la efectividad inicial de la institución de su cumplimiento (de acuerdo con el viejo aforismo: «el modo constriñe pero no suspende y la condición suspende pero no obliga»). Es importante comprender esta diferencia porque en los artículos del Código a veces se habla de condición cuando se quiere hacer referencia al modo (arts. 647 y 798.II CC); y, por otra parte, el artículo 797.I CC establece que, en caso de duda, entre modo y condición potestativa, ha de entenderse que el testador ha querido instituir *sub modo*. Las SSTS 18.7.11 y 3.3.21 (RJ 5217 y 969) demuestran, en cualquier caso, la difusa línea de separación que existe entre uno y otro tipo de institución.

Scanned with CamScanner

No existen más límites para el contenido de la carga modal que el de que el acto u omisión en la que consista sea lícito y posible; de otro modo, al igual que la condición, se tendrá por no puesta (aunque lo primero es más que discutible, la jurisprudencia ha entendido que la posibilidad del modo debe referirse al momento del otorgamiento y al de la muerte del testador, STS 10.5.91 —RJ 9815). Respecto al beneficiario de la misma, la mayor parte de la doctrina entiende que este debe encontrarse definido de manera genérica (SSTS 28.594 —RJ 6723— y 17.7.96 —RJ 5800), pues si este fuese determinado de forma individualizada nos encontraríamos ante un legado.

Como ya se ha señalado, el instituido *sub modo* tiene derecho a adquirir y hacer efectiva la atribución en el mismo momento en que lo tiene cualquier instituido de manera pura y simple. En cuanto al momento en que debe cumplirse con la carga modal, esta resulta exigible desde ese mismo momento, salvo disposición en contra del testador (art. 797. II CC). Su contenido ha de ser cumplido en los términos en los que lo haya ordenado el testador. Solo cuando el cumplimiento exacto definido por el testador no sea posible, a causa de circunstancias ajenas a la culpa del gravado, se podrá ejecutar en otros términos «*los más análogos y conformes a su voluntad*» (art. 798.I CC), siempre que sea posible (vid. la STS 3.3.21 —RJ 969, sobre la carga modal de cuidar del testador, algo que ya no resulta posible tras la muerte de éste). El cumplimiento podrá ser exigido por los herederos, los albaceas y los terceros favorecidos (en cuanto son interesados en que se cumpla el modo).

Las consecuencias del incumplimiento de la carga modal por parte del instituido varían en función de cuales sean las causas o circunstancias en que se haya producido. Si el instituido gravado falleciera antes de cumplir, la obligación no se extingue, sino que se transmite a sus herederos. En caso de que el modo no se cumpliese a causa de que resulta imposible sobrevenidamente ejecutar la prestación modal, este se considerará cumplido cuando la imposibilidad no se deba a culpa del instituido. Y ello tanto si el interesado en que se cumpla lo ha impedido (art. 798 CC), como si la imposibilidad se debe a otras causas (STS 10.5.91 —RJ 9815). Por último, si el cumplimiento de la carga se ha hecho imposible por culpa del instituido, no hay acuerdo acerca de la procedencia de la obligación de restituir lo percibido. Ahora bien, lo que es indudable es que, sea o no imposible definitivamente el cumplimiento de la carga modal, el instituido *sub modo* que incumple su obligación en los términos del artículo 1101 CC, está sujeto a la responsabilidad patrimonial derivada de su incumplimiento, dentro de los límites propios del tipo de institución de que se trate.

El artículo 797.II CC, con carácter dispositivo, establece que tanto el instituido como, en su caso, sus herederos (aunque este precepto solo mencione a los herederos, esta obligación por su propia finalidad debe

Scanned with CamScanner

entenderse exigible también del instituido *sub modo*) habrán de prestar fianza en los términos del artículo 797.II para asegurar el cumplimiento de lo mandado por el testador y para la devolución de lo percibido con sus frutos e intereses. El afianzamiento de lo mandado por el testador se refiere a la responsabilidad por los daños derivados del incumplimiento del modo, y su constitución, de no hacerse voluntariamente, puede ser exigida por los legitimados para pedir el cumplimiento de la carga. En cuanto a la devolución de lo percibido y los frutos e intereses, procederá solo si se entiende que el incumplimiento de la carga modal concreta de que se trate debe tener ese efecto restitutorio. Algunos autores entienden que esto sucede siempre, lo cual hace difícil distinguir al modo de la condición (la misma fianza se prevé en el artículo 800 *in fine* CC para instituciones condicionales). Otros entienden que ello solo se produce cuando el cumplimiento del modo es el motivo determinante de la institución.

4.2. La institución de heredero y el legado

La primera y más importante de las eventuales disposiciones que puede contener un testamento es, como ya se ha señalado, la institución de heredero. Pese a su trascendencia, la institución de heredero en el Derecho español común, a diferencia de lo que sucedía en el Derecho romano, no constituye un contenido esencial del testamento. Así lo señala expresamente el artículo 764 CC que dispone que el testamento será válido, aunque no contenga institución de heredero, o esta no comprenda la totalidad de los bienes, y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar; y se deriva del artículo 891 CC que permite la distribución de toda la herencia en legados.

En todo caso, como se ha indicado en el Tema 1.4, nadie fallece sin heredero, por lo que el problema que plantea un testamento en el que no se ha designado uno es el de determinar, salvando el supuesto del artículo 891 CC que acabamos de mencionar, a quién le corresponde esta condición. La respuesta a este problema determinará, a su vez, qué sucede con todos los bienes, derechos y obligaciones incluidos en el caudal hereditario de los que no se ha dispuesto. Para estos casos, y también en contra de la regla romana de que nadie podía morir en parte testado y en parte intestado, lo procedente en Derecho español es cumplir con las disposiciones que el testador haya hecho en el testamento, y para lo restante abrir la sucesión intestada (art. 764 CC, *vid.*, al respecto de esta cuestión el Tema 2.1.4).

Otra cuestión que debe ser resuelta en relación con la institución de heredero es la consistente en conocer cuándo estamos ante una disposición de esta naturaleza. En este sentido, la figura del heredero, además de por su *nomen iuris*, se caracteriza por ser un sucesor a título universal. La concurrencia en una disposición testamentaria de estas dos señas de identidad típicas del heredero (denominación y carácter universal

Scanned with CamScanner

del llamamiento que se le efectúa) deben conducir necesariamente a la calificación de la misma como una institución de heredero (STS 22.1.63 —RJ 447), a no ser que claramente se pueda deducir otra cosa de la voluntad del causante. Por otra parte, como es natural, también la presencia de uno solo de estos dos elementos servirá como indicativo de que la voluntad del causante era instituir al beneficiario de la disposición como heredero. En todo caso, el Código Civil parece otorgar preeminencia al elemento objetivo de la institución a título universal, al disponer, por un lado, que, en la duda, aunque el testador no haya usado la palabra heredero, valdrá la disposición a título universal o de herencia (art. 668 CC); y, por otro lado, que si el testador designa a un heredero en cosa cierta y determinada, se entenderá como legatario (art. 768 CC y STS 25.11.2014 —RJ 6006; en la SSTS 5.2.73 —RJ 405— se consideró que un legado universal de bienes constituía, *a contrario*, una institución de heredero). En todo caso, estas dos disposiciones que se acaban de relacionar se han declarado de naturaleza meramente interpretativa por el Tribunal Supremo (STS 9.3.93 —RJ 2053) y, por ende, susceptibles de ser desechadas si consta una voluntad distinta del testador.

No están vedadas, por consiguiente, con todas las salvedades que se acaban de expresar, en el Derecho español, ni la figura del legado de parte alícuota de la herencia, esto es, un legado que atribuye al legatario una cuota parte del caudal hereditario (de hecho, esta figura se encuentra expresamente reconocida hoy en día en los artículos 782.1, 783.2 y 793.3 LEC, y a un legado de parte alícuota se refiere la RDGRN 20.7.07 —BOE 17.8), ni la del heredero de una cosa cierta. Ahora bien, la disposición testamentaria a través de la que se instituye heredero *ex re certa* o legatario de parte alícuota habrá de ser especialmente clara pues, de otra forma, el riesgo de que se interprete en un sentido diverso del deseado por el testador es ciertamente elevado. Así las cosas, la institución del heredero *ex re certa* ha de mostrar claramente la voluntad de nombrar a un sucesor en una cuota de la herencia (un sucesor universal) y que en pago de esa cuota se le atribuye un bien particular de la misma, y por su parte, la institución del legatario de parte alícuota debe mostrar que lo que se pretende es instituir a una persona a título particular en una determinada cuota de bienes.

Por lo demás, resultan aplicables tanto a la institución de heredero, como al legado (arts. 789 y 790 CC), todas las disposiciones que hemos identificado como el régimen jurídico general o común de las disposiciones testamentarias.

4.3. Otras disposiciones susceptibles de incorporarse al contenido del testamento

Además de la institución de heredero y del legado, existen otras múltiples disposiciones típicas y atípicas, instrumentales y sustantivas que

Scanned with CamScanner

pueden componer el contenido del testamento. De cualquier modo, para tratarse de disposiciones testamentarias en sentido estricto, han de tener un contenido imperativo, debiendo distinguirse de las meras admoniciones, ruegos o consejos que el testador dirige a los destinatarios de su voluntad, sin exigirles su cumplimiento.

Dentro de estas disposiciones testamentarias de carácter secundario, debemos distinguir un primer grupo compuesto por las disposiciones de naturaleza instrumental y accesoria. Se trata de disposiciones con las que el testador determina, con carácter vinculante, cómo han de llevarse a cabo o cómo deben entenderse sus disposiciones principales. En este sentido, es frecuente que en los testamentos se incluyan disposiciones referentes a cómo se debe efectuar la colación o a la partición de la herencia, designando o determinando como ha de nombrarse a los albaceas, fijando el orden en que deben ser pagados los legados, o decidiendo cómo deben reducirse las donaciones inoficiosas.

Al margen de las que se han señalado, existen otras disposiciones testamentarias, vinculadas a derechos de naturaleza extrapatrimonial o personal, que constituyen lo que se conoce como contenido anómalo o atípico del testamento (STS de 23.6.2015 —RJ 4484), por más que alguna de ellas haya obtenido un reconocimiento legal (así sucede con el reconocimiento testamentario de la filiación en el art. 741 CC). Las más importantes de estas disposiciones son, además de la que se acaba de señalar: la designación de un tutor para el hijo menor (art. 213 CC), la constitución de una fundación, el consentimiento para la fecundación *post mortem*, la designación de las personas que hayan de ejercitar las acciones de protección del honor, intimidad y propia imagen, o las relativas a la divulgación, paternidad e integridad de la obra del autor fallecido. A medio camino entre estas disposiciones atípicas y las patrimoniales típicas está la designación de la persona a la que se debe entregar el animal de compañía del causante (art. 914 bis I CC), dado que las mascotas tienen actualmente un régimen jurídico ambiguo en el que aparecen como objeto de propiedad privada, y al mismo tiempo como objeto de deberes de cuidado y protección que encajan mal con el derecho de propiedad.

El problema fundamental que plantean estas disposiciones es el de determinar si realmente constituyen disposiciones testamentarias, o si se trata, en el fondo, de disposiciones no testamentarias efectuadas bajo la forma de un testamento. La cuestión no es baladí, pues de una respuesta positiva o negativa depende el régimen jurídico de las mismas, tanto en lo que se refiere a su validez inicial, como a su eventual revocabilidad por otro testamento. En este sentido, lo que es seguro es que la disposición a través de la que se reconoce la filiación no se ve afectada por la nulidad o revocación del testamento en el que se efectúa (art. 741 CC). ¿Cabe concluir entonces que este tipo de disposiciones no siguen el régimen aplicable a las disposiciones testamentarias?

Scanned with CamScanner

A nuestro modo de ver, en cuanto a las reglas de fondo aplicables a estas disposiciones anómalas, parece que lo más correcto, y así lo ha hecho el legislador en el artículo 741 CC, es que estas se rijan por las normas específicamente previstas para la clase de actos o negocios jurídicos a la que pertenecen. De esta manera, la disposición anómala de que se trate será solo revocable o nula, si el acto o negocio jurídico que contiene también lo es. Así las cosas, el nombramiento de un tutor podrá revocarse, porque la tutela no se constituye hasta que se dicte una sentencia firme que contenga la designación del tutor; pero no sucede lo mismo con el reconocimiento de la filiación, pues, hecho este en una de las formas admitidas en Derecho, la filiación queda automáticamente determinada (art. 120 CC).

No está de más precisar que los comúnmente llamados testamentos vitales (técnicamente denominados «documentos de instrucciones previas») a los que se refieren las normas sobre autonomía del paciente (Ley 41/2002 y normas autonómicas concordantes) no son testamentos en sentido técnico ni, por lo tanto, siguen el régimen jurídico descrito en esta lección. Se trata de documentos en los que la persona manifiesta su voluntad por adelantado acerca de los cuidados y tratamientos médicos que desea que le presten —o que no le presten— cuando ya no pueda decidir por sí misma, así como el destino que quiere que se le dé a sus órganos y su cuerpo. Por consiguiente, ni todas las declaraciones de voluntad contenidas en un testamento vital son disposiciones mortis causa (los cuidados que se quieren recibir en vida obviamente no lo son), ni las que lo son están sujetas a las reglas sobre negocios jurídicos testamentarios, sino a las que resultan aplicables a la declaración de voluntad en particular de que se trate (a la donación de órganos o a la decisión sobre el uso del cadáver).

5. LA INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO

Con frecuencia se afirma que, entre las dificultades prácticas que plantea el negocio jurídico testamentario, la mayor es la de interpretarlo. Frente a lo que sucede con los negocios jurídicos *inter vivos*, en el testamento, el autor de la declaración de voluntad negocial ha fallecido, y ello implica que el intérprete está privado de la fuente de información más importante para dilucidar el sentido y significado de las disposiciones que contiene. No es de extrañar, entonces, que en la jurisprudencia las resoluciones en materia de interpretación superen con mucho a las vertidas sobre cualquier otra cuestión atinente al testamento.

El Código Civil dedica un solo artículo a la regulación de la interpretación del testamento: «toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará lo

Scanned with CamScanner

que aparezca más conforme a la intención del testador según el tenor del mismo testamento» (675 CC). De este precepto, deben extraerse las claves para realizar una interpretación correcta de las disposiciones testamentarias. De entre estas claves, sin duda, la más evidente es el predominio de la voluntad del testador.

5.1. El fin de la interpretación: la averiguación de la voluntad real del testador

El fin esencial de la interpretación en materia testamentaria es el de averiguar cuál es la que el Tribunal Supremo ha denominado *voluntad real* del testador (STS 9.6.87 —RJ 4049). La condición de negocio jurídico unilateral del testamento implica que la trascendencia que posee la determinación de la voluntad de la única parte del negocio en orden a su correcta interpretación, es superior a la importancia que posee la investigación de la voluntad de las partes en el ámbito contractual (SSTS 26.4.97 —RJ 3542 y 18.7.98 —RJ 6388). En consecuencia, las palabras empleadas por el testador no pueden nunca suponer un obstáculo para que prevalezca su auténtica voluntad, aunque estas constituyan normalmente el punto de partida de la interpretación (SSTS 18.7.05 —RJ 5339— y 3.3.2023 —RJ 1164).

De conformidad con lo expuesto, la interpretación del testamento es de naturaleza absolutamente subjetivista. El intérprete debe situarse en todo momento en la perspectiva subjetiva del testador para tratar de deducir su verdadera voluntad (STS 31.12.96 —RJ 9380). Concretamente, debe situarse en el momento temporal en el que el testamento fue otorgado (STS 21.1.03 —RJ 604), no siendo relevante, de por sí, la voluntad manifestada por el testador en los momentos previos a su fallecimiento. El testamento es un negocio jurídico perfecto en el momento en que se otorga de conformidad con las formalidades previstas, y no resulta modificado por un simple cambio de voluntad del testador, si esta no se ha manifestado mediante una revocación válidamente realizada del mismo.

No se puede acudir a la interpretación auténtica ya que se puede preguntar al testador su voluntad

5.2. Medios o elementos de interpretación testamentaria

Más allá de lo dispuesto en el artículo 675, no se ha incluido en el Código Civil norma alguna sobre interpretación testamentaria. La falta de una regulación más extensa sobre la materia, ha hecho surgir la duda acerca de la posibilidad de aplicar al testamento las normas sobre interpretación de los contratos. A este respecto, y sin perjuicio de que se han declarado aplicables a la interpretación del testamento algunos de los cánones o medios de interpretación contenidos en los artículos 1281 y siguientes CC, el TS ha declarado reiteradamente que esta normativa no

Scanned with CamScanner

puede ser empleada en bloque para la interpretación testamentaria (STS 23.6.98 —RJ 4746). Es preciso, por lo tanto, determinar cuáles son los cánones, medios o elementos que deben emplearse para interpretar los testamentos, y así lo ha ido haciendo el TS a través de sus resoluciones:

1.º El canon o elemento literal o gramatical. Las palabras con las que se ha expresado la declaración de voluntad testamentaria constituyen el punto de partida de la interpretación del testamento. En principio, se presume que estas reproducen fielmente la voluntad del testador (STS 18.7.05 —RJ 5339). Si se hubiesen empleado términos técnico-jurídicos ha de considerarse *prima facie* el significado técnico de los mismos y no su eventual significación en la esfera de lo profano (STS 31.12.92 —RJ 10426). Ahora bien, estas reglas solo son de aplicación cuando no conste una voluntad distinta del testador. En este sentido, el Tribunal Supremo suele acudir a otros expedientes de averiguación de la voluntad cuando las palabras empleadas por el testador sean oscuras (STS 10.12.09 —RJ 2010/279 y 18.3.11 —RJ 3323). En todo caso, las palabras deben entenderse desde una óptica subjetivista, situándose el intérprete en la posición y el ambiente dentro del que fueron utilizadas (STS 31.12.96 —RJ 9380), siempre con el fin de atribuirles el significado más acorde con la intención del autor (SSTS 21.1.03 —RJ 604— y 6.6.2014 —RJ 3127).

2.º Los cánones o elementos sistemático, lógico y finalista. Estos tres medios de interpretación deben ser empleados conjunta y armónicamente, partiendo de la consideración del contenido del testamento como una unidad (SSTS 9.3.84 —RJ 1206—, 31.12.92 —RJ 10426— y 9.1.03 —RJ 7232).

3.º Los medios de prueba extrínsecos. La utilización de medios de prueba extrínsecos o externos a la manifestación de voluntad testamentaria ha sido admitida, desde hace largo tiempo, por la jurisprudencia (STS 8.7.40 —RJ 689). Habida cuenta de que el objetivo fundamental de la interpretación testamentaria es la búsqueda de la verdadera voluntad del testador (la *voluntad real*), cuando esta puede derivarse con facilidad de circunstancias exteriores al testamento, resulta aconsejable el uso de estos medios extrínsecos, que, aun así, han de utilizarse con cierta cautela (STS 6.10.94 —RJ 7461). Los actos extrínsecos del testador relevantes a estos efectos son los coetáneos, anteriores o inmediatamente posteriores al testamento (como en las SSTS 3.3.21 —RJ 969 y 3.3.2022 —RJ 1164). La alegación de circunstancias alejadas en el tiempo de la manifestación de voluntad testamentaria, suele rechazarse por el TS debido a su fuerte componente conjetural (STS 29.12.97 —RJ 9490).

4.º Normas supletorias y específicas de interpretación. A lo largo de la regulación del fenómeno sucesorio en el Código Civil, nos encontramos frecuentemente con la presencia de normas de carácter interpretativo, que atribuyen un determinado significado a oraciones o palabras

Scanned with CamScanner

empleadas en los testamentos (véanse, entre otros, los arts. 747, 749, 751, 768 a 772 y 779 y 780 CC). Todas estas normas deben considerarse presunciones *iuris tantum* de que la prevista en cada precepto es la voluntad del testador.

5.3. La integración de la voluntad testamentaria

Es perfectamente posible que en un testamento aparezcan lagunas en su contenido dispositivo. Por esta razón tiene todo el sentido preguntarse acerca de la posibilidad de integrar en tales casos el contenido del testamento, supliendo de algún modo los vacíos existentes en el mismo. Sin embargo, la respuesta a la cuestión que se acaba de plantear ha sido unánimemente negativa tanto en la doctrina[8] como en la jurisprudencia. El motivo del rechazo a la integración del contenido del testamento radica en que el carácter formal y personalísimo del negocio testamentario excluye toda posibilidad de completar el testamento por parte del intérprete (STS 8.6.40 —RJ 689).

Ahora bien, fuera de la órbita de esta prohibición se situaría la denominada interpretación integradora (que no es integración, sino interpretación) consistente en extender la voluntad real del testador a puntos no expresamente previstos por él. Con ella, no se trata de suplir la voluntad del causante, sino interpretar qué es lo que había decidido presumiblemente en relación con aquellos puntos sobre los que expresamente no se pronunció. La jurisprudencia no solo no ha prohibido la utilización de este tipo de interpretación, que no considera, con razón, más que una variante de la interpretación sistemática, lógica y teleológica, sino que incluso subraya su necesidad en los casos en que el testador haya sido especialmente parco (SSTS 26.11.74 —RJ 4490— y 22.7.94 —RJ 6578).

6. AVERIGUACIÓN DE LA EXISTENCIA Y EJECUCIÓN DEL TESTAMENTO: EL ALBACEAZGO

6.1. El Registro de actos de última voluntad

Una vez que se ha producido el fallecimiento de una persona, la primera cuestión que se plantea a los interesados en su sucesión es la de conocer si el difunto había o no otorgado testamento u otras disposiciones por causa de muerte. Igualmente, en los casos en los que se sabe que el causante ha testado en distintas ocasiones, reviste una importancia decisiva conocer cuál de los diversos testamentos es el último y, por tanto, en caso de ser válido y eficaz, ha de regir la sucesión.

[8] Vid. por todos, JORDANO BAREA, J.B., El testamento y su interpretación, Ed. Comares, Granada, 2001, p. 102.

Con el objeto de dotar de la máxima seguridad jurídica posible a los eventuales sucesores testamentarios se creó en España el Registro de actos de última voluntad. Se trata de un Registro público, de carácter informativo, cuya misión es la de proporcionar información acerca de si una persona fallecida ha otorgado o no actos de última voluntad que se hayan registrado.

El Registro no garantiza la validez ni la autenticidad de los actos y negocios registrados, y no excluye la posibilidad de que existan otros testamentos o disposiciones *mortis causa* que sustituyan a los registrados (piénsese, por ejemplo, en un testamento ológrafo posterior a todos los notariales otorgados por el difunto que constan en el Registro). Sin embargo, constituye un elemento muy útil para conocer la última voluntad del difunto, ya que la mayor parte de los testamentos que se otorgan en la práctica son notariales.

Esta institución se organiza mediante un Registro Central, al que llegan todas las tarjetas remitidas por los notarios, conteniendo la identificación del otorgante, la fecha del otorgamiento y los datos que permiten la identificación del instrumento en la Notaría de que se trate; un Registro intermedio por cada Colegio Notarial y un Registro particular en cada Notaría. El Registro emite, a petición de los interesados, certificaciones en las que se hacen constar, sin garantizar su validez o autenticidad, todos los actos de última voluntad registrados, atribuidos a la persona de la que se solicita la información.

6.2. La ejecución testamentaria: el albacea

La ejecución testamentaria, como cualquier ejecución de un negocio jurídico, consiste en llevar a cabo las distintas disposiciones y contenidos del testamento, cumpliendo de forma fiel y rigurosa con la voluntad del testador. En este sentido, los primeros a quienes compete realizar la ejecución del testamento es a los herederos (art. 911 CC —a los herederos impropiamente se les llama en ocasiones «albaceas legítimos»). Sin perjuicio de ello, en el Código se regula con detalle una figura cuya función es esencialmente la de ejecutar y velar por el cumplimiento de la voluntad del testador. Este ejecutor de la voluntad testamentaria recibe en nuestro Derecho el nombre de albacea.

6.2.1. Concepto y caracteres del albaceazgo

El albacea es el ejecutor del testamento, designado por el testador a causa de la especial confianza que le merece. No se trata propiamente de un mandatario, pues no media relación contractual entre el albacea y el testador, ni tampoco de un representante del causante, porque, ob-

viamente no se puede representar a quien carece ya de personalidad, aunque a veces pudiera dar la impresión de que estamos ante una u otra figura. La jurisprudencia ha señalado que el de albacea es un cargo u oficio, si bien de naturaleza privada, fundado en la confianza del causante (SSTS 20.2.93 —RJ 1004— y 20.9.99 —RJ 6361), y que como tal puede ser fiscalizado por el juez y por la propia ley. Aceptando esta caracterización jurisprudencial, las notas que definen el cargo de albacea son las siguientes:

1.º Es un cargo voluntario. El albaceazgo se constituye solo cuando el albacea haya aceptado, expresa o tácitamente, su nombramiento. Ahora bien, a falta de aceptación expresa o tácita, la ley otorga el valor de aceptación del albaceazgo al simple silencio del designado en el testamento, si no rechaza el cargo dentro de los seis días siguientes a aquel en que tenga noticia de su nombramiento o, si este le era ya conocido, dentro de los seis días siguientes al en que supo la muerte del testador (art. 898 CC). Debe advertirse que, tanto la no aceptación del cargo, como la renuncia al mismo después de haber aceptado, sin justa causa (art. 899 CC), aunque son facultades del albacea, producen consecuencias jurídicas negativas para él. En concreto, el albacea perderá lo que le hubiese dejado el testador, limitándose su participación en la herencia, en su caso, a lo que le corresponda por legítima estricta (art. 900 CC). La renuncia con justa causa no produce efectos negativos para el albacea. Esta deberá hacerse ante notario o letrado de la administración de justicia, a cuyo criterio se deja la apreciación de la justicia de la causa que se alegue (art. 899 CC).

2.º Es un cargo personalísimo. Naturaleza que, por lo demás, es connatural a los cargos de confianza. No cabe por consiguiente que el albacea delegue sus funciones en otra persona, a no ser que expresamente se lo haya autorizado el testador (art. 909 CC). Ello no excluye que el albacea pueda proveerse de auxiliares o colaboradores para proceder a la ejecución de sus funciones. Lo que no puede hacer, de ningún modo, es desentenderse de las mismas encomendándole la realización de sus tareas a terceros (STS 20.9.99 —RJ 6361).

3.º Es un cargo gratuito. El albacea no obtendrá remuneración alguna por el desempeño de su cargo, salvo que el testador haya dispuesto que se le remunere. Si el testador la hubiese dispuesto, la cuantía de la remuneración será la fijada por el causante. Cuando fuesen varios los albaceas y el testador hubiese señalado una cantidad única para todos ellos, esta cantidad se repartirá íntegra entre los albaceas que hayan aceptado su cargo. Por consiguiente, en estos supuestos de cantidad alzada para todos los albaceas, la parte correspondiente a los que rechacen o renuncien a su cargo acrecerá a los demás (art. 908 CC). Si la remuneración fijada por el testador fuese excesiva, el exceso deberá computarse como legado, y seguir el régimen jurídico de este tipo de dis-

posiciones *mortis causa*. Cuestión distinta de la remuneración del cargo, es el pago por los eventuales servicios facultativos o profesionales que pudiera desempeñar el albacea con ocasión del ejercicio de sus funciones. Respecto de este problema, el Código Civil establece la posibilidad de que albacea cobre lo que le corresponda por «*los trabajos de partición y otros facultativos*» (art. 908 CC). La doctrina y el Tribunal Supremo entienden que estos trabajos de carácter facultativo solo se pueden realizar —y cobrar— por parte del albacea cuando él mismo ostenta la condición de facultativo o profesional (STS de 14.1.13 —CL 1913-19, vol. 1.º). En otro caso, lo procedente es que el albacea encargue esos trabajos a un tercero, pues a él no le resulta exigible hacerlos ni tiene la competencia profesional precisa para realizarlos.

4.º Es un cargo temporal. El albacea debe cumplir con su encargo en el tiempo señalado por el testador o por la ley (arts. 904 a 906 CC).

6.2.2. *Clases de albaceas*

Universales y particulares. Por razón de las funciones que les haya atribuido el testador, se distingue entre los albaceas universales y los albaceas particulares (art. 894 CC). El albacea universal es aquel que tiene atribuidas todas las facultades precisas para ejecutar la voluntad testamentaria, desde la muerte del causante hasta la adjudicación y entrega de los bienes que integran el caudal hereditario. Ello implica que el albacea universal no es un mero ejecutor testamentario, sino que además ostentará las atribuciones propias de los contadores-partidores y de los administradores de la herencia. El albacea particular, por el contrario, es aquel al que le ha sido encomendada solo la realización de tareas concretas en relación con la ejecución del testamento, o aquel al que se le han conferido únicamente determinadas facultades limitadas o específicas relativas a la herencia. Por otra parte, es perfectamente posible designar a un albacea universal y a varios albaceas particulares, encargados de tareas específicas; e incluso a varios albaceas (particulares o universales) para que desplieguen su actividad de forma sucesiva en el tiempo (los llamados albaceas sucesivos, *ex* art. 897 CC).

Albaceas mancomunados y solidarios. Cuando el testador decide nombrar a más de un albacea, salvo disposición en contrario, se entiende que actúan conjuntamente. En tal caso, rige la regla general favorable a la mancomunidad, exigiéndose para que la relación sea solidaria una disposición clara del testador (art. 897 CC). Los albaceas mancomunados deben actuar de consuno, bien con autorización de los que no actúan o, en caso de disidencia y solo previa deliberación de todos los designados, de acuerdo con la regla de la mayoría (art. 895 CC, STS 7.11.2018 —RJ 4921). Únicamente, en supuestos de «*suma urgencia*» podrá actuar unilateralmente uno de los albaceas; eso sí, dando cuen-

posiciones *mortis causa*. Cuestión distinta de la remuneración del cargo, es el pago por los eventuales servicios facultativos o profesionales que pudiera desempeñar el albacea con ocasión del ejercicio de sus funciones. Respecto de este problema, el Código Civil establece la posibilidad de que albacea cobre lo que le corresponda por «*los trabajos de partición y otros facultativos*» (art. 908 CC). La doctrina y el Tribunal Supremo entienden que estos trabajos de carácter facultativo solo se pueden realizar —y cobrar— por parte del albacea cuando él mismo ostenta la condición de facultativo o profesional (STS de 14.1.13 —CL 1913-19, vol. 1.º). En otro caso, lo procedente es que el albacea encargue esos trabajos a un tercero, pues a él no le resulta exigible hacerlos ni tiene la competencia profesional precisa para realizarlos.

4.º Es un cargo temporal. El albacea debe cumplir con su encargo en el tiempo señalado por el testador o por la ley (arts. 904 a 906 CC).

6.2.2. *Clases de albaceas*

Universales y particulares. Por razón de las funciones que les haya atribuido el testador, se distingue entre los albaceas universales y los albaceas particulares (art. 894 CC). El albacea universal es aquel que tiene atribuidas todas las facultades precisas para ejecutar la voluntad testamentaria, desde la muerte del causante hasta la adjudicación y entrega de los bienes que integran el caudal hereditario. Ello implica que el albacea universal no es un mero ejecutor testamentario, sino que además ostentará las atribuciones propias de los contadores-partidores y de los administradores de la herencia. El albacea particular, por el contrario, es aquel al que le ha sido encomendada solo la realización de tareas concretas en relación con la ejecución del testamento, o aquel al que se le han conferido únicamente determinadas facultades limitadas o específicas relativas a la herencia. Por otra parte, es perfectamente posible designar a un albacea universal y a varios albaceas particulares, encargados de tareas específicas; e incluso a varios albaceas (particulares o universales) para que desplieguen su actividad de forma sucesiva en el tiempo (los llamados albaceas sucesivos, *ex* art. 897 CC).

Albaceas mancomunados y solidarios. Cuando el testador decide nombrar a más de un albacea, salvo disposición en contrario, se entiende que actúan conjuntamente. En tal caso, rige la regla general favorable a la mancomunidad, exigiéndose para que la relación sea solidaria una disposición clara del testador (art. 897 CC). Los albaceas mancomunados deben actuar de consuno, bien con autorización de los que no actúan o, en caso de disidencia y solo previa deliberación de todos los designados, de acuerdo con la regla de la mayoría (art. 895 CC, STS 7.11.2018 —RJ 4921). Únicamente, en supuestos de «*suma urgencia*» podrá actuar unilateralmente uno de los albaceas; eso sí, dando cuen-

ta de inmediato a los demás, y asumiendo personalmente las responsabilidades que pudieran derivarse de su actuación. Cuando alguno de los albaceas mancomunados que se hayan nombrado no sea capaz para desempeñar el cargo, no lo acepte, renuncie, fallezca o sea removido del mismo, el (o los) que se mantengan continuarán desempeñando el cargo concentrando en él (o ellos) las funciones del que no lo haga.

En lo que se refiere a los albaceas solidarios, ante la carencia de una regulación legal, la doctrina y la jurisprudencia excluyen la posibilidad de que se les apliquen las reglas de las obligaciones solidarias. En principio, el albacea solidario que haya decidido llevar a cabo una actuación debe comunicar a los demás su intención. Si los demás albaceas desisten expresa o tácitamente de intervenir o no pueden participar en el mismo (STS 23.11.74 —RJ 4445), el albacea que haya tomado la iniciativa y los que a él se unan podrán prestar un consentimiento válido y eficaz en relación con la actuación de que se trate. Por el contrario, si alguno de los albaceas solidarios se opone a la actuación que pretende llevar a cabo el que toma la iniciativa, habrá que acudir a la regla de la mayoría en caso de que, tras la oportuna deliberación, los albaceas involucrados no lleguen a un acuerdo. Se trata, en definitiva, de un régimen jurídico menos exigente que el de los albaceas mancomunados para la realización de actuaciones válidas y eficaces por uno solo o parte de los albaceas. Es un régimen, en cierto modo, similar al establecido en el artículo 1693 CC en el que el socio administrador puede actuar por sí solo, salvo que cualquiera de los otros se oponga.

6.2.3. Capacidad y contenido del cargo de albacea

El artículo 893.I CC exige la capacidad para obligarse para poder acceder al cargo de albacea. En todo caso, se prohíbe a los menores sujetos a patria potestad o tutela acceder a este cargo, quedando la duda de si esta prohibición afecta también a los menores emancipados. De lo que no debe caber duda es de que los discapacitados, en principio, si podrán ser albaceas, aunque para ello deban recurrir a las medidas de apoyo que les permitan el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica (249 CC). Las prohibiciones para suceder no afectan a la capacidad para ser albacea (STS 24.5.54 —RJ 1325), ni tampoco le afecta la sola presencia de una causa de indignidad. En todo caso, en relación con las causas de indignidad, lo que sí es relevante es el hecho objetivo que da lugar a la indignidad, pues su presencia muchas veces implica que ha dejado de existir la confianza que el causante depositaba en el albacea y provocar su remoción.

El albacea tiene como misión fundamental la de cumplir con su encargo, que será distinto, en función de que se trate de un albacea universal o particular, y en el último caso, de cuál sea el contenido de sus

Scanned with CamScanner

cometidos. El cumplimiento del encargo debe efectuarse, en todo caso, con sujeción estricta a las órdenes del testador y cumpliendo con lo dispuesto en el testamento, incluso cuando hacerlo pueda ser dudoso jurídicamente (la STS 3.9.2014 —RJ 4795 entendió que el albacea que aplica una cautela socini en sus propios términos actúa correctamente aunque se haga con infracción de la jurisprudencia sobre este tipo de cláusulas).

En principio, para cumplir con su encargo, el albacea ostenta todas aquellas facultades que el testador le haya atribuido expresamente, siempre que no sean contrarias a las leyes (art. 901 CC, STS 5.1.12 —RJ 174). En este sentido, deben entenderse conferidas al albacea no solo las facultades expresamente relacionadas como tales en el testamento, sino también aquellas cuya atribución al mismo se deduzca en virtud de una correcta interpretación del testamento (STS 19.6.58 —RJ 2496).

En caso de que el testador no haya dispuesto, expresa o implícitamente, cuáles son las facultades del albacea, la ley le atribuye solo las contenidas en los artículos 902 y 903 CC (que deben ser completadas con otras dispersas por todo el ordenamiento, como las expresadas en los arts. 747 y 749 CC y en el art. 9.4.º de la Ley 50/2002, de Fundaciones). La DGRN entiende que para realizar actos de disposición sobre los bienes de la herencia, el albacea debe contar siempre con el consentimiento de los legitimarios (RDGRN 25.1.1990 —RJ 112). Tras la aprobación de la LJV, también puede pedir autorización judicial, si fuese pertinente, empleando el procedimiento del art. 91 de dicha Ley.

El albacea, sea cual fuere el contenido de sus funciones y facultades, debe desempeñar el cargo, desde su aceptación, con la diligencia de un buen padre de familia situado en su misma posición (art. 1104 CC). En caso de que de las acciones u omisiones realizadas con ocasión del desempeño de su cargo se deriven daños a los favorecidos en el testamento, el albacea será responsable civil de los mismos, siempre que haya actuado con dolo o negligencia (pudiendo incluso incurrir, en determinados casos, en una conducta delictiva como la prevista en el art. 440 CP).

En cuanto al plazo de cumplimiento del encargo, es obligación de todo albacea la de realizar su tarea en el plazo señalado por el propio testador o, en defecto de término dispuesto por el causante, en el plazo de un año contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o alguna de sus disposiciones (art. 904 CC). El plazo señalado en el testamento y el fijado por la ley son susceptibles de prórroga. Esta prolongación del plazo solamente es posible cuando el propio testador lo haya previsto, cuando así lo decida el notario o secretario judicial o cuando lo concedan los herederos y legatarios, todo ello en los términos establecidos en los artículos 904 y 905 del CC. El TS admite la prórroga implícita del

Scanned with CamScanner

cargo de albacea cuando la voluntad de que continúe se puede deducir de los actos propios de los sucesores (v.gr. cuando le permiten realizar todos sus actos después de caducado su mandato, STS 7.11.2018 —RJ 4921). La finalización del plazo y, en su caso, de la prórroga determina automáticamente la extinción del albaceazgo. No es posible impedir que este efecto automático se produzca alegando impedimentos u obstáculos procedentes de los favorecidos por el testamento o de los familiares del difunto, ni influyen en el cómputo del plazo controversias judiciales distintas de las expresamente aludidas por el artículo 904 CC.

6.2.4. *La extinción del albaceazgo y la rendición de cuentas*

El albaceazgo se extingue, en primer lugar, por el cumplimiento del encargo encomendado por el testador al albacea (STS 5.1.12 —RJ 174), y además, por las causas señaladas en el artículo 910 CC: la muerte del albacea, la imposibilidad de cumplir con el encargo, la renuncia o remoción del albacea y el transcurso del plazo concedido para terminar el encargo.

La renuncia del albacea ya ha sido tratada al hilo de la exposición de los caracteres del albaceazgo y también lo ha sido el transcurso del término o plazo, al abordar el contenido del cargo de albacea, por lo que prescindiremos ahora de la explicación referente a estas dos cuestiones. En relación con las demás, debe resaltarse lo siguiente.

La muerte del albacea como causa de extinción del albaceazgo es una consecuencia natural del carácter personalísimo de este cargo. De todos modos, no debe confundirse la extinción del albaceazgo con la de las obligaciones y derechos patrimoniales vinculados al mismo (el derecho a la remuneración, o la responsabilidad patrimonial derivada del incumplimiento de sus obligaciones), que sí son transmisibles a los herederos.

La imposibilidad de continuar en el desempeño de sus funciones, que también extingue el albaceazgo, debe ser entendida como la concurrencia de una causa psicofísica (una enfermedad mental o física inhabilitante para desarrollar las actuaciones propias del albaceazgo), que impida al albacea continuar realizando su cometido (STS 2.12.91 —RJ 8899).

La remoción, a diferencia de lo que sucede con la renuncia, solo puede ser apreciada por el juez (art. 910 CC). En cuanto a los motivos por los que el albacea puede ser removido de su cargo, el Código no los señala. Ha tenido que ser la jurisprudencia la encargada de determinar cuáles son estas causas de remoción, atendiendo a la naturaleza y funciones del albacea (STS 3.9.2014 —RJ 4795). En este sentido, se

Scanned with CamScanner

han considerado motivos justificativos de la remoción, entre otras, a la presencia en el albacea de hechos determinantes de indignidad para suceder desconocidos por el testador, que contradigan la confianza depositada en el nombrado (STS 13.4.93 —RJ 3103), la realización de acciones dolosas o negligentes perjudiciales para el caudal o los sucesores del causante (SSTS 3.10.31 —RJ 2173— y 23.2.73 —RJ 536), y también la constatación de un conflicto de intereses entre el albacea y los herederos que ponga en peligro la adecuada realización de su tarea (STS 13.4.92 —RJ 3103). Por lo demás, el Tribunal Supremo, en alguna ocasión, ha indicado que pueden servir como apoyo para resolver los problemas de remoción del albacea, las causas señaladas para la remoción de los tutores (STS 13.4.92 —RJ 3103). La remoción se lleva a cabo en expediente de jurisdicción voluntaria, de conformidad con las normas procedimentales del art. 91 LJV.

Tras haber finalizado el albaceazgo, la persona o personas que lo han desempeñado deben necesariamente rendir cuentas de su tarea, sin que ni siquiera el testador pueda impedirlo (art. 907 CC). La rendición de cuentas se realiza, con carácter general, ante los herederos; mediante la presentación por parte del albacea de un informe de su gestión y las cuentas, si las hay, generadas por sus actuaciones. Solo si los albaceas hubiesen sido investidos con la facultad de aplicar o distribuir los bienes entre sujetos indeterminados, en los casos en que la ley lo permita (arts. 671, 747 y 749 CC), rendirán cuentas ante el juez. En este supuesto, el procedimiento será también el regulado en el art. 91 de la LJV. En caso de que el albacea no hubiese cumplido con sus obligaciones con el grado de diligencia exigible, responderá de los daños derivados de dicho incumplimiento en los términos del artículo 1101 CC. Si después de concluida la tarea del albacea se producen disputas entre los sucesores, tales controversias no resucitan la función del albacea y deberán ser ventiladas entre los propios sucesores (STS 5.1.12 —RJ 174).

7. EFICACIA E INEFICACIA DEL TESTAMENTO

Sin perjuicio de que, como ya se ha señalado, los negocios jurídicos *mortis causa*, y entre ellos el testamento, pueden producir efectos antes de la muerte del causante (e incluso todos sus efectos, como sucede en el caso del testamento meramente revocatorio de otro anterior), lo normal es que su eficacia se traslade al momento en que el testador fallece.

Esta duplicidad de momentos temporales en los que se produce, por una parte, la perfección del testamento y, por otra parte, el inicio de sus efectos jurídicos, conduce a que muchos de los vicios o circunstancias que influyen en la eficacia del testamento deban ser valorados en relación con el momento de su perfección (así, la capacidad del testador, o la falta de vicios en la declaración del testador), o con otros momentos

Scanned with CamScanner

anteriores al inicio de sus efectos (como sucede con su eventual revocación por otro testamento, o su caducidad en determinados supuestos).

En línea de principio, se ha dicho que son necesarios cuatro presupuestos para que un testamento adquiera la eficacia *post mortem* que le es propia: 1.º Que se haya producido la muerte del testador; 2.º Que el testamento se haya presentado (en aquellos supuestos en que así está establecido); 3.º Que el testamento sea válido (que no incurra en ningún motivo de nulidad) y 4.º Que el testamento esté vigente (que no haya caducado o haya sido revocado).

Debe advertirse que el hecho de que un testamento sea válido y eficaz no supone necesariamente que tenga que regir la sucesión del testador. Al igual que sucede con todos los negocios jurídicos, su cumplimiento puede devenir sobrevenidamente imposible. En ocasiones esto sucederá por circunstancias o sucesos ajenos a la voluntad del ser humano, como en el caso de la muerte del único heredero designado en el testamento, acaecida antes del fallecimiento del causante. Otras veces será la voluntad de los sucesores, que repudian el testamento sin que se les haya designado un sustituto, la que impide la eficacia testamentaria. De cualquier modo, no debe olvidarse que la misión fundamental del intérprete del testamento es siempre la de darle a la voluntad del testador la máxima eficacia que sea posible.

7.1. El testamento inválido

El tercero de los requisitos de eficacia del testamento enumerados en los párrafos anteriores exigía que el testamento fuese válido. Podemos caracterizar al testamento válido, como aquel otorgado por quien está legitimado para ello, en el que están presentes todos sus elementos esenciales carentes de vicios, y cuyo contenido, además, no es contrario las normas imperativas, a la moral ni al orden público (art. 255 CC). Cuando un testamento no reúne estas condiciones es inválido y, como consecuencia de ello, ineficaz.

Más allá de estas afirmaciones generales, predicables de cualquier negocio jurídico, el problema que plantea la ineficacia del testamento en el Derecho común español, cuando esta se deriva de su falta de validez, es el de determinar el régimen jurídico aplicable a la misma. El Código Civil no contiene una regulación general de la ineficacia del testamento o de las disposiciones *mortis causa*. Por otra parte, no son útiles para resolver los problemas relativos a la ineficacia del testamento por invalidez, las normas que componen la teoría general de contrato, al menos en bloque, pues la estructura unilateral y no recepticia del negocio jurídico testamentario rechaza esa aplicación (SSTS 12.11.64 —RJ 5080— y 3.10.79 —RJ 3235).

Scanned with CamScanner

La primera duda que surge al cuestionarse el tratamiento jurídico que cabe dar a los distintos supuestos de invalidez del testamento, es la de si puede hablarse, en este ámbito, de la misma dualidad de regímenes aplicables a la invalidez contractual: la nulidad radical o de pleno Derecho y la anulabilidad. En este sentido, y pese a que importantes autores de nuestra doctrina han defendido la tesis dualista, el régimen de anulabilidad de los negocios jurídicos no parece coherente con la idiosincrasia del negocio jurídico testamentario. En efecto, el régimen de anulabilidad tiene como fin el de proteger a una de las partes de un negocio jurídico que se ha celebrado cuando esa parte era incapaz para consentir, con su consentimiento viciado o sin su participación (1301 *in fine* CC). Teniendo en cuenta que el testador es la única parte del negocio jurídico testamentario, y que este ya ha fallecido cuando se enjuicia la validez del testamento, no parece que este régimen de anulabilidad en sede testamentaria tenga sentido, pues difícilmente se conseguirá con el mismo proteger al testador.

En definitiva, la invalidez del testamento, sea cual fuere su causa, da lugar a la aplicación del régimen de nulidad radical, absoluta o de pleno Derecho. A partir de aquí, el problema fundamental será el de determinar las causas que, en concreto, producen la nulidad del testamento, y cuándo esa nulidad es total o parcial.

7.1.1. Causas de nulidad del testamento y su alcance: la nulidad total y la nulidad parcial

El artículo 743 CC establece un principio de interpretación restrictiva de las causas o motivos que producen la nulidad del testamento, explicitando que las disposiciones testamentarias solo serán ineficaces, en todo o en parte, «*en los casos expresamente prevenidos en este Código*». En aplicación de este principio restrictivo, reconocido por la jurisprudencia (STS 12.11.64 —RJ 5080), suelen enumerarse, como causas que determinan la nulidad del testamento, las que se relacionan a continuación: 1.º Falta de capacidad del testador (art. 663 CC); 2.º Inobservancia de las formalidades establecidas para cada clase de testamento (art. 687 CC); 3.º Otorgamiento de testamento con violencia, dolo o fraude (art. 673 CC); 4.º Infracción de las prohibiciones expresamente establecidas en el Código Civil en relación al otorgamiento de testamentos (prohibición de testar mancomunadamente o por comisario, prohibición de introducir límites a la revocabilidad del testamento); y finalmente 5.º Infracción de las normas sobre legítimas o reservas, en la medida en que no pueda ser subsanada a través de la reducción de la disposición inoficiosa.

Cuando un testamento incurre en alguna de estas causas de nulidad, es posible calificar esta nulidad como total y también como parcial. La

Scanned with CamScanner

consecuencia de la nulidad total, sería la ineficacia completa del negocio, mientras que la nulidad parcial supondría la ineficacia restringida a una o varias de sus cláusulas. La nulidad, por otro lado, dará lugar, en cualquier caso, al conocido efecto de nulidad en cadena, por el cual todos los actos y negocios que encuentren su causa o fundamento en el negocio nulo o en la cláusula testamentaria nula son también nulos de pleno derecho. Esto sucedería, por ejemplo, con la partición y adjudicación de bienes fundada en un testamento totalmente nulo o en una cláusula testamentaria nula, así como con los eventuales actos de enajenación de los bienes hereditarios adjudicados en virtud de ellos. Si los bienes adjudicados no fuesen recuperables, el TS ha declarado que deberá devolverse el precio de la venta de los mismos (STS 28.4.2014 —RJ 3284).

Volviendo a la cuestión de cuándo debe entenderse que la nulidad de un testamento es total o parcial, *prima facie*, la ley parece favorable a la nulidad parcial, y ello no solo por el juego de los principios señalados en el párrafo anterior. La jurisprudencia se ha pronunciado abiertamente a favor de la nulidad parcial sobre la base del principio de conservación de los actos y negocios como principio general del derecho (STS 3.9.2014 —RJ 4795). De hecho, el propio Código establece en gran cantidad de ocasiones la nulidad parcial como remedio frente a numerosas contravenciones normativas en que ha podido incurrir el testador (así sucede en los arts. 675.II, 737.II, 750, 752 a 754, 792 y 814 CC), ordenando tener por no puesta, única y exclusivamente, a la disposición testamentaria contraria a la ley. Ahora bien, la sanción de nulidad parcial es aplicable cuando la causa de nulidad repercute solo en una o varias de sus disposiciones que no impiden el mantenimiento del resto del negocio (SSTS 12.11.64 —RJ 5080— y 3.10.79 —RJ 3235). Por el contrario, no se puede declarar la nulidad parcial si la causa afecta a la totalidad del testamento o a una parte esencial del mismo.

Así las cosas, la falta de capacidad del testador, los vicios de la voluntad testamentaria y el incumplimiento de las formalidades previstas, al influir en uno de los elementos esenciales del testamento y, por consiguiente, en todo el negocio jurídico, darán lugar a la nulidad total. Esto no significa, de todos modos, que cualquier infracción cometida a través de una disposición testamentaria concreta sea siempre motivo de nulidad parcial. En efecto, aunque la nulidad parcial sea el remedio más habitual en estos casos, debe quedar excluida cuando la disposición nula se encuentre tan íntimamente relacionada con el restante contenido negocial, que su nulidad deba conllevar necesariamente la de todo el testamento. Para valorar esta íntima relación entre la disposición nula y el restante contenido testamentario, será fundamental determinar cuál hubiese sido la voluntad del testador de haber conocido la nulidad de la cláusula en cuestión. Si se demuestra que el testador no querría la conservación del resto del testamento sin la cláusula nula, el negocio

Scanned with CamScanner

jurídico habrá de reputarse totalmente nulo, y viceversa. Solo deberá desatenderse este criterio en el caso de que la propia ley ordene (como sucede en el art. 792 CC).

7.1.2. La acción de nulidad del testamento

La nulidad del testamento constituye un ejemplo de nulidad radical o absoluta. Por consiguiente, la sentencia que determina la nulidad del negocio o de parte de su contenido tiene carácter declarativo. Además, cabe la apreciación de oficio por parte del Tribunal encargado de enjuiciar, por cualquier motivo, el testamento o las disposiciones testamentarias nulas, siempre dentro del respeto de la regla constitucional que prohíbe la indefensión (STS 14.10.97 —RJ 7408). Por lo demás, conforme a su naturaleza, la acción de nulidad en sí misma es imprescriptible, aunque las que sí pueden prescribir son las eventuales acciones de condena (acciones de petición de herencia, de suplemento de legítima, etc.), que puedan encontrar su fundamento en la declaración de nulidad.

Están legitimados activamente para pedir la nulidad del testamento todos los interesados en que se declare su invalidez. Este grupo de sujetos, en abstracto, estará integrado, al menos, por los eventuales herederos abintestato (que heredarían por ministerio de la ley a falta de testamento o de las disposiciones testamentarias de que se trate), por los designados en un testamento anterior que recuperaría su vigencia si se estimase la acción de nulidad y, en general, por todas aquellas personas que estuviesen legitimadas para entablar acciones de condena sobre la base de la sentencia que declara la nulidad. No lo está, sin embargo, el tutor para anular un testamento por falta de capacidad del testador cuándo este todavía no ha fallecido (STS 23.3.10 —RJ 2326).

La legitimación pasiva la ostentarán los designados sucesores (herederos o legatarios) o los favorecidos por el testamento a los que pueda afectar la nulidad. Entre todos ellos existe litisconsorcio pasivo necesario (SSTS 10.11.79 —RJ 4655— y 21.2.94 —RJ 1104).

Pese a que la doctrina afirma lo contrario, por corresponderle la defensa de la validez del testamento en juicio y fuera de él, la jurisprudencia no estima necesario que se demande al albacea (SSTS 30.9.64 —RJ 4100— y 24.7.05 —RJ 5603). Tampoco es preciso demandar al notario autorizante, aun cuando el defecto del que se derive la nulidad sea de forma y atribuible al mismo. Ahora bien, su falta de legitimación pasiva en la acción de nulidad no es óbice para que el notario pueda ser declarado responsable, en otro proceso, por el incumplimiento de su obligación de velar por un otorgamiento ajustado a las solemnidades requeridas para cada testamento (arts. 705 y 715 CC).

Scanned with CamScanner

Una última cuestión que debe ser tratada en relación con la acción de nulidad es la referente a la posibilidad de que el testador intente limitar su ejercicio a través de las denominadas cláusulas o cautelas *prohibitorias* de impugnación del testamento. Este problema lo resuelve el último párrafo del artículo 675 CC, en el que se dispone que el testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley. Ello implica la interdicción de aquellas típicas cláusulas que pretenden impedir el ejercicio de la acción de nulidad por parte de un heredero forzoso, normalmente con la sanción de quedar el impugnante abocado a recibir solo lo que le corresponda por legítima estricta. Con todo, la jurisprudencia matiza que este precepto no debe ser aplicado de forma automática y rigorista, debiéndose ponderar singularmente la estipulación testamentaria de que se trate, para delimitar hasta dónde debe llegar, en cada caso, la invalidez. De cualquier manera, no cabe, por medio de estas cautelas, tratar de impedir por parte del testador la impugnación de disposiciones concretas contrarias a la ley o que perjudiquen la legítima (STS 3.3.80 —RJ 1016).

7.1.3. La convalidación y la conversión del testamento nulo

Pese a que, de acuerdo con la teoría general de las nulidades, el negocio jurídico radicalmente nulo no es, en principio, convalidable; esto es, no puede recobrar la validez, aunque así lo quieran los perjudicados a causa de la disposición nula; lo cierto es que doctrinal y jurisprudencialmente se habla de la posibilidad de convalidar un testamento. En concreto, se ha admitido la convalidación del testamento cuando el mismo es: a) inicialmente aceptado como válido, expresa o tácitamente, por un sucesor legitimado para ejercitar la acción de nulidad; b) posteriormente impugnado por uno de los que lo han aceptado como válido, mediante el ejercicio de una acción con la que pretende obtener la declaración de nulidad del mismo; y c) siempre que se trate de defectos de forma del testamento y no de una nulidad por incumplimiento de prohibiciones legales (SSTS 9.7.86 —RJ 4425—, 28.7.86 —RJ 4621— y 26.4.9 5 —RJ 3257).

Menos problemática, por ser conforme con la teoría general de las nulidades y por encontrarse expresamente acogida en el Código, es la posibilidad de conversión del testamento nulo. El artículo 715 CC establece que el testamento cerrado, nulo por falta de cumplimiento de las formalidades exigidas para el mismo, puede mantener su validez como testamento ológrafo si todo él estuviese escrito y firmado por el testador y tuviere las demás condiciones propias de este testamento. Se trata de un supuesto de conversión meramente formal: el testamento que no ha respetado los requisitos formales de uno de los tipos legalmente previstos (el testamento cerrado), puede ser considerado válido, si reúne todos los exigidos por otro tipo de testamento (el ológrafo).

Scanned with CamScanner

7.2. La revocación del testamento

Entre los caracteres definitorios del testamento se encuentra el de ser un negocio jurídico esencialmente revocable (art. 737.I CC). Esta esencial revocabilidad del testamento se funda en que se trata del producto de la libertad individual de testar del causante, de la que disfruta hasta el momento de su fallecimiento, y también en el hecho de que sus efectos fundamentales se producen después de la muerte del otorgante.

La facultad del testador de revocar el testamento es tan connatural al mismo que ni siquiera el propio testador puede limitar la posibilidad de revocar su propio testamento hacia el futuro. Precisamente para evitar cualquier tipo de cautelas o limitaciones en este sentido, el artículo 737. II CC ordena que se tengan por no puestas las cláusulas derogatorias de las disposiciones futuras, y aquellas en que ordene el testador que no valga la revocación del testamente si no la hiciere con ciertas palabras o señales.

En sí misma considerada, la revocación constituye un negocio jurídico que debe estar revestido de los mismos caracteres que identifican a cualquier disposición testamentaria. La revocación es, por consiguiente, unilateral y personalísima, y además, debe ser realizada con idénticas solemnidades a las prescritas para los testamentos (art. 738 CC). Tampoco debe caber duda acerca de su naturaleza *mortis causa*, y ello con independencia de que los efectos de la revocación se produzcan con carácter inmediato a su realización y, por tanto, antes de la muerte del causante.

La capacidad para realizar la revocación es también la misma que se requiere para testar, con la excepción de la revocación real o presunta. Por lo tanto, en esta materia habrá que estar a las disposiciones contenidas en los artículos 662 a 666, y 688 CC —en relación a la revocación en forma ológrafa.

7.2.1. Clases de revocación testamentaria

La revocación es, como todo negocio jurídico, una declaración de voluntad del testador destinada a producir como efecto la pérdida de vigencia de un testamento anterior. Esta voluntad revocatoria del testador puede manifestarse de tres maneras diversas: de forma expresa, tácita o presunta. La primera modalidad consiste en una declaración en la que el testador manifiesta expresamente su voluntad de que el testamento anterior quede sin efecto. La segunda en el otorgamiento por parte del testador de un nuevo testamento que, de un modo u otro, se ha querido incompatible con el anterior. Por fin, la tercera, también llamada revocación real o material, se produce como consecuencia de la destrucción

Scanned with CamScanner

material del testamento realizada por el testador con el propósito de dejarlo sin efecto.

Las tres modalidades enunciadas agotan las posibles formas de revocar el testamento en el Derecho español común. Esto significa que no puede deducirse una voluntad revocatoria eficaz de ningún otro acto o conducta del testador, por más reveladora que pudiera parecer.

La revocación expresa. Para ser eficaz habrá de realizarse en un nuevo testamento válido y, por lo tanto, otorgado con todas las solemnidades requeridas por la ley. No es preciso que se trate del mismo tipo de testamento que el que se pretende revocar (un testamento cerrado puede revocarse mediante un testamento abierto u ológrafo), pero sí que se hayan respetado todas las solemnidades establecidas para la validez del que contiene la declaración expresa de voluntad revocatoria (art. 738 CC). Tampoco es necesario que se utilice el término «revocación» u otros similares, sino que basta con que conste claramente la voluntad del testador de dejar sin efecto el testamento previo. La declaración revocatoria puede disponer la revocación total o parcial del testamento, manteniendo, en este último caso, su vigor las disposiciones no afectadas por la revocación. Asimismo, puede constituir el único contenido del testamento, con lo cual se abrirá la sucesión intestada en relación con la parte del testamento que haya sido revocada; o estar unida a una nueva ordenación *mortis causa* de las relaciones jurídicas del testador.

La revocación presunta. Este tipo de revocación se regula en el artículo 739 CC, que establece la pérdida automática de vigor del testamento anterior por efecto del otorgamiento de otro posterior válido si el testador no expresa en este su voluntad de que aquel subsista en todo o en parte. Pese al rigor con el que parece exigir el Código la expresión de voluntad del testador relativa a la subsistencia del testamento anterior, la jurisprudencia ha declarado en varias ocasiones que no es precisa la existencia de una manifestación expresa de voluntad para que se produzca este efecto (STS 12.7.02 —RJ 8581). Es razonable, además, esta posición jurisprudencial si se piensa, por ejemplo, en que el otorgamiento del nuevo testamento puede obedecer a la simple intención de completar, aclarar o complementar el contenido del testamento previo. En cualquier caso, la eventual convivencia entre varios testamentos siempre está supeditada a que todos los que al mismo tiempo se encuentren en vigor sean compatibles, en el sentido de que sea factible la ejecución conjunta de todos ellos para disciplinar la sucesión (STS 1.2.88 —RJ 581— y 7.5.90 —RJ 3687). Por último, en materia de revocación presunta, debe hacerse referencia a la posibilidad de reviviscencia del testamento revocado por obra de un testamento posterior que declare «expresamente», que es voluntad del testador que valga de nuevo el primero (art. 739.II CC).

Scanned with CamScanner

La revocación real o presunta. Su regulación se encuentra en el artículo 742 CC, el cual dispone que se presume revocado el testamento cerrado que aparezca en el domicilio del testador con las cubiertas rotas, o los sellos quebrantados, o borradas, raspadas o enmendadas las firmas que lo autoricen. Se trata, por consiguiente, de una revocación presunta que, en principio, parece afectar solo al testamento cerrado; aunque no encontramos razón alguna para no entender revocado a un testamento ológrafo que haya sufrido agresiones similares a las descritas en el 742 CC por parte del testador. En todo caso, lo que parece evidente es que es indispensable demostrar que la destrucción del testamento, en cualquiera de las formas descritas por el precepto, debe ser el producto de una actuación consciente e intencionada del testador, no produciendo efecto revocatorio ni las destrucciones por negligencia, por muy grave que sea, ni las fortuitas (art. 742.II CC).

7.2.2. *Efectos de la revocación testamentaria*

El efecto de la revocación de un testamento, en cualquiera de las modalidades expuestas, es su pérdida de eficacia inmediata. Este efecto se extenderá a todo el testamento cuando la revocación sea total (lo cual sucede siempre, en el caso de la revocación real), y solamente a las partes que el testador ha querido privar de vigor, en el caso de la revocación parcial. En todo caso, el artículo 741 CC excluye de los efectos de la revocación del testamento a la disposición a través de la cual se reconoce a un hijo.

7.3. La caducidad del testamento

El Código dispone la caducidad de determinados tipos o modalidades testamentarias. La caducidad supone la ineficacia automática de estos testamentos, por imperativo legal, como efecto del transcurso de plazos diversos.

En algunos casos la caducidad se produce porque se han superado las circunstancias extraordinarias en las que el testamento se otorgó. Por esta razón caducan: a) Los testamentos otorgados en inminente peligro de muerte o en caso de epidemia (art. 703 CC); b) El testamento militar (arts. 719 y 720 CC); c) Los testamentos marítimos (arts. 730 y 731 CC). En otros supuestos, la razón de la caducidad se encuentra en el incumplimiento de formalidades complementarias tendentes a asegurar la autenticidad del mismo. Así sucede con el testamento ológrafo (art. 689 CC), el testamento en caso de epidemia (art. 703 CC), el testamento militar (art. 720 CC), y los testamentos marítimos (art. 731 CC).

Scanned with CamScanner

8. LA SUCESIÓN CONTRACTUAL

8.1. Caracterización de los pactos o contratos sucesorios

Se denomina sucesión contractual a aquella que es deferida a través de acuerdos negociales entre el causante y los instituidos. Estos negocios jurídicos bilaterales o plurilaterales *mortis causa*, de naturaleza contractual, a través de los que se ordena la sucesión de una persona se conocen con el nombre de contratos o pactos sucesorios.

La nota más trascendente del pacto o contrato sucesorio, la que lo diferencia netamente del negocio testamentario, es que en el pacto sucesorio la voluntad del causante se encuentra vinculada por otra voluntad distinta: la del que celebra el negocio con él. Esto supone que la ordenación sucesoria que contiene el contrato no puede revocarse libre y unilateralmente por el causante. Por el contrario, con carácter general, cualquier revocación o modificación en el contenido del pacto sucesorio solo podrá efectuarse con el consentimiento de los mismos sujetos que intervinieron en su celebración.

Doctrinalmente, se distinguen dos clases principales de auténticos pactos sucesorios: a) los pactos de institución o afirmativos, a través de los que el causante instituye herederos o legatarios, u ordena la institución de un heredero forzoso; y b) los pactos renunciativos o negativos, mediante los que, en su modalidad más importante, uno de los herederos forzosos del causante renuncia a su participación en la herencia del mismo, a cambio de una contraprestación en vida.

Los pactos o contratos sucesorios se caracterizan, además de por su naturaleza bilateral o plurilateral y su consiguiente irrevocabilidad por negocios unilaterales del causante, por tratarse de negocios personalísimos y, normalmente, de carácter formal o solemne.

Una vez concertado el pacto sucesorio de acuerdo con las formalidades establecidas para ello, el causante vinculado por el mismo tiene limitada por el contenido del pacto su libertad de disponer por causa de muerte. Por consiguiente, cualquier testamento que otorgue, por muy posterior que sea a la celebración de contrato sucesorio, no será válido en cuanto contradiga las estipulaciones del pacto.

8.2. La prohibición de los pactos sucesorios en el Derecho común español

El artículo 658 CC, al determinar los modos en los que puede deferirse la sucesión, se limita a señalar al testamento y, a falta de este, a lo ordenado en la ley. Esta limitación de los modos de suceder al testamen-

Scanned with CamScanner

to y a la sucesión legal o intestada, que excluye, por tanto, la posibilidad de que la herencia se defiera mediante pacto o contrato, se cohonesta perfectamente con lo dispuesto en otros preceptos del Código (arts. 816, 991, 1271.II y 1674 CC).

De todos los preceptos señalados en el párrafo anterior, se extrae el principio que inspira el Código en la materia que nos ocupa, y que no es otro que el de prohibir no solo la sucesión contractual, sino también el fenómeno de los pactos sucesorios en general. La consecuencia de la vigencia del principio prohibitivo es que, por regla general, los contratos o pactos sucesorios son radicalmente nulos en el Derecho civil común. Este rechazo a los pactos o contratos sucesorios está fundado únicamente en la tradición romanista asumida por nuestro Derecho desde las Partidas. En la actualidad gran parte de la doctrina aboga por la introducción de este modo de ordenar la sucesión en el Derecho común (así en la Propuesta de Código Civil de la APDC, arts. 463-1 a 12). Además, de forma excepcional, encontramos en el Derecho común vigente, algunas normas que establecen la validez de ciertos pactos sucesorios, eso sí, de manera muy limitada (vid. los artículos 826 CC, 827 o 1341.II CC).

Por otra parte, pese a la innegable vigencia del principio prohibitivo y de la consiguiente nulidad de los pactos sucesorios con las pocas excepciones que acabamos de relacionar, lo cierto es que la jurisprudencia ha interpretado de forma bastante relajada estas reglas jurídicas. En concreto, ha declarado en reiteradas ocasiones que son válidos los contratos que tengan por finalidad, no disponer *mortis causa* sobre universalidad de la herencia, sino respecto bienes concretos que ya se encuentran en el patrimonio del cedente cuando se celebra el acuerdo (SSTS 25.4.51 —RJ 1615— y 22.7.97 —RJ 5807). En aplicación de esta doctrina, se han declarado válidos, entre otros, contratos o pactos por causa de muerte como los siguientes: la disposición por el reservatario de su derecho en relación con una herencia ya deferida pero antes del fallecimiento del reservista (STS 18.4.42 —RJ 470); la disposición por el fideicomisario de su derecho, en tanto que, como heredero del fideicomitente, dispone sobre una herencia ya abierta (STS 3.3.64 —RJ 1254); o la donación de nuda propiedad de bien ganancial reservándose el donante y su cónyuge el usufructo vitalicio, conjunto y sucesivo (RDGRN 21.1.91 —RJ 592).

BIBLIOGRAFIA. ÁLVAREZ LATA, N. «Comentario de los arts. 667 a 675», en BERCOVITZ, R. (Dir.) Comentarios al Código Civil, Ed. Thomson-Aranzadi, 2021 (5ª edic.). CAPILLA RONCERO, F. «Nulidad e impugnabilidad del testamento», ADC, 1987-I. DÍAZ ALABART, S. El testamento ológrafo de las personas mayores dependientes, Ed. Reus, Madrid, 2018. GARCÍA VICENTE, J.R. «El testamento mancomunado: razones para la derogación del art. 669 del Código Civil», en AA.VV. Derecho de sucesiones. Presente y futuro. XII Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho civil, Ed. SP de la Universidad de Murcia,

Scanned with CamScanner